חוברת 1 · סיכום מלא

דיני חוזים

הסיכום המקיף

מושגים, סעיפי חוק, פסקי דין, טבלאות השוואה וטיפים למבחן

16 פרקים

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

סיכום לפי פרקים

1 שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

2 העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

3 מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

4 הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

5 תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

6 תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

7 צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

8 פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

9 פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

10 חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

11 חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ״ג-1982)

12 חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

13 חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

14 הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

15 תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

16 פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

פרק 1

שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

1.1 מבוא: מהו חוזה, ולמה לא כל הסכם הוא חוזה

דיני החוזים הם המערכת שדרכה המדינה – באמצעות המחוקק ובתי המשפט – קובעת את הכללים: איך חוזה נוצר, מתי יש לו תוקף מחייב ומה קורה כשמישהו מפר אותו. דבר מפתיע: בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, אין הגדרה למושג "חוזה". החוק קופץ ישר להסביר איך חוזה נכרת (הצעה וקיבול) בלי להסביר מהו הדבר עצמו. ההגדרה נולדה בפסיקה, ממקרים שבהם הסכמים השתבשו והגיעו לבית המשפט.

✦ הגדרה — חוזה

חוזה = הסכם משפטי. המילה המכריעה היא "משפטי": לא כל הסכמה בין בני אדם היא הסכם משפטי. בחיי היומיום יש הסכמות משפחתיות, חברתיות, מוסריות או "ג'נטלמניות" שאיש לא התכוון להכפיף למערכת המשפט.

✎ דוגמה — שני סטודנטים וטיסה לחו"ל

לפני מבחנים נותרו 11 ימים פנויים. שני סטודנטים מחליטים לטוס לחו"ל, נפגשים כל יום ללמוד בשעות 16:00–19:00, וכותבים בקובץ וורד בשם "חוזה" שמי שיחמיץ פעמיים את הלימוד ישלם לשני את עלות הטיול (600 דולר). שניהם חותמים. אחד נעדר פעמיים והחבר תובע. **האם השופט יחייב לשלם?** האינטואיציה אומרת "כן" (יש הסכמה, כתב, חתימה, סנקציה), אבל המשפט אומר: לא כל הסכם הוא חוזה. כדי להבין למה צריך את שני "שומרי הסף" שנלמד עכשיו.

דימוי הארמון

כדי לזכור את המבנה, הקורס משתמש בדימוי: דיני החוזים הם **ארמון**. צדדים שערכו הסכם והוא השתבש מבקשים להיכנס בשערי הארמון כדי שבית המשפט יכריע. בפתח עומדים **שומרי סף**, ורק מי שעבר אותם נכנס:

1. **כוונה ליצור יחסים משפטיים** (שומר סף ראשון)
2. **שפיטות** (שומר סף שני)
3. **כשרות משפטית** (נושא נפרד: קטינים, פסולי דין ועוד; נלמד בהרחבה במקום אחר בקורס)

אחרי שעוברים את שומרי הסף נכנסים ל**קומה הראשונה** של הארמון – פרק א' לחוק החוזים (חלק כללי), שלב המשא ומתן – שעוסקת בשני נושאים נפרדים לגמרי (ראו פרקים 2–6):

נושא	השאלה	ייתכן שבלעדיו
כריתת חוזה	האם נכרת חוזה? (גמירת דעת + מסוימות)	שני רמאים כורתים חוזה תקף
תום לב במשא ומתן	האם הצדדים נהגו בהגינות? (סעיף 12)	אנשים הגונים מאוד נפרדים בלי חוזה

★ טיפ למבחן — להפריד בין שתי השאלות

במבחן שואלים לעיתים "האם נכרת חוזה?" ובשאלה נפרדת "האם נהג בחוסר תום לב?". אל תערבבו. ייתכן שלא נכרת חוזה והייתה התנהגות שלא בתום לב (פיצויים), וייתכן שנכרת חוזה ואחד הצדדים נהג שלא בתום לב.

1.2 שומר סף ראשון: כוונה ליצור יחסים משפטיים

✦ הגדרה — כוונה ליצור יחסים משפטיים

מצב שבו, בזמן עריכת ההסכם, שני הצדדים התכוונו שהקשר ביניהם יהיה קשר **משפטי** – כזה שאם תהיה הפרה אפשר לפנות לבית המשפט – ולא רק קשר חברי, מוסרי, משפחתי או של כבוד. אם רק צד אחד רצה קשר משפטי – אין חוזה.

✎ דוגמה — המתווך ובעל הדירה

בעל דירה נתן למתווך בלעדיות וקבע שדמי התיווך ישולמו על ידי הקונה בלבד. אחרי יותר משנה של מאמצים לשווא, ברגע של ייאוש משותף בסלון, הבטיח: "אם תמצא קונה, אשלם לך דמי תיווך גם מכיסי". הדירה נמכרה, והבעלים סירב לשלם וטען שזו "מחווה חברית" ללא כוונה משפטית. אם בית המשפט משתכנע שההבטחה ניתנה במישור המוסרי-חברי בלבד – אין חוזה.

איך בודקים כוונה? שני שלבים

שלב א׳ – הביטוי המפורש. בית המשפט בוחן מה הצדדים אמרו או כתבו. אם הצהירו "אנו מעוניינים בקשר משפטי" או "אין בכוונתנו ליצור יחסים משפטיים" – ברוב המקרים בית המשפט יכבד זאת. (המילים "ברוב המקרים" חשובות: ראו לוין נ׳ לוין להלן.)

שלב ב׳ – מבחני עזר. כשהצדדים לא התייחסו במפורש, השופט "נכנס לראש שלהם" ושואל: אילו הייתי יושב שם, מה אדם סביר היה מבין מהתנהגותם?

מבחן עזר	מצביע על כוונה משפטית	מצביע על העדר כוונה
נסיבות עריכת ההסכם	נחתם במשרד עורכי דין, עם ייעוץ משפטי	נאמר בצעקות על רחבת ריקודים בחתונה
השפה	לשון מסודרת וכתובה: "הפרה", "פיצויים", "בית משפט", "סעדים" (אין חובה לשפה משפטית, זו אינדיקציה)	ניסוח חופשי, שיחתי
היחסים בין הצדדים	זרים, יחסי עסקים (נקודת מוצא, לא כלל מוחלט)	קרובים, בני משפחה, חברים טובים
נושא ההסכם	כסף, מסחר, עסקים, נכסים	חברי, רוחני, דתי

! שים לב — דברים שבלב – אינם דברים

בית המשפט לא מחפש מה באמת היה בלב הצדדים אלא מה משתקף החוצה: איך התנהגו, היכן חתמו, באילו מילים השתמשו, מה היחסים ומה נושא ההסכם. אותו עיקרון יחזור בפרק 2 (העדה על גמירת דעת).

1.3 לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93): כשהכוונה והשפיטות נפגשות

⚖ פסק דין — לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)

הפסק הקלאסי של הנושא. מומלץ לקרוא אותו במלואו.

העובדות

בני זוג נשואים כ-8 שנים, הורים לילדים, החליטו להיפרד. הם פנו יחד לעורכת דין אחת כדי לחסוך בעלויות, וערכו שני הסכמים קשורים: **הסכם א׳** לתקופה שבה הם עדיין נשואים (עד מתן הגט) ו**הסכם ב׳** לתקופה שאחרי הגט. הנושא המרכזי: סכום חודשי שהבעל מתחייב לשלם לאישה, גבוה יותר בתקופה הראשונה ונמוך אחרי הגט. ההסכמים נוסחו בלשון משפטית ואף כותרתם "חוזה". אבל בהסכם א׳ הוסיפו הצדדים, בלשון משפטית מסורבלת, סעיף שאין ברצונם ליצור קשר משפטי.

הבעל שילם בהתחלה ואז הפסיק. הצטבר חוב, והאישה תבעה. בינתיים ניתן הגט, והסכם ב׳ נכנס לתוקף (אין עליו מחלוקת). הוויכוח נותר על התקופה הראשונה: האם הסכם א׳ הוא חוזה?

"התיקו" והפתרון

- **לכיוון "אין כוונה":** כתוב במפורש שאין כוונה ליצור קשר משפטי. לפי הכלל הרגיל, מה שכתבת הוא מה שהתכוונת.
- **לכיוון "יש כוונה":** כל מבחני העזר – עורכת דין, לשון משפטית, כותרת "חוזה", בני זוג בהליכי גירושין (לא "שטויות פרטיות"), נושא כספי של מזונות ותמיכה.

המשקל נוטה לשני הכיוונים בערך שווה – "תיקו". בית המשפט אינו יכול לומר "אינני יודע", ולכן קבע כלל מנחה: אם איני מצליח להכריע בשאלת הכוונה, אפנה לשיקולי שפיטות ומדיניות משפטית – האם מבחינה חברתית-ציבורית ראוי שבית המשפט ידון בהסכם הזה? כאן השיקולים חזקים: מעורבות ילדים, צד חלש הזקוק להגנה, חשיבות הסדרת מזונות ותמיכה בתקופה רגישה. לכן קבע בית המשפט שהשפיטות מושכת לדיון, ו"חזר אחורה" וקבע שגם הכוונה התקיימה. **התוצאה: יש כוונה, יש שפיטות, יש חוזה, והבעל חויב לשלם.**

מה באמת קורה בראש השופט (ההיבט הביקורתי)

סביר שהשופטים הבינו שהצדדים באמת לא רצו קשר משפטי להסכם א׳, אבל חשו חובה לדון בו מטעמי ערכי החברה. במקום לומר "לא אכפת לנו מה רציתם", בחרו בנוסחה רכה: "ניסינו לחפש את הכוונה ולא הצלחנו, ולכן פונים לשפיטות". המסקנה: שומרי הסף אינם עובדים בטור אלא במקביל. בפועל, שיקולי השפיטות כבר משפיעים על האופן שבו השופט קורא את הכוונה.

★ טיפ למבחן — מה זה אומר לעורך דין

אם מייצגים בעל כמו לוין, לא מספיק לצעוק "כתוב שאין כוונה!". צריך לפעול בשני מישורים: (1) לשכנע שלא הייתה כוונה; (2) לשכנע שמבחינת שפיטות לא נכון שבית המשפט יתערב. ורק אם משכנעים בשניהם יש סיכוי שהסכם לא ייחשב חוזה.

שתי תובנות נוספות מהפסק

- **המחיר החברתי של כפיית משפטיות:** אם כל הסכמה מוסרית נדיבה שתיכתב תהפוך לחוזה, עורכי דין ינחו לקוחות "אל תתחייבו". אנשים יימנעו מלנהוג לפנים משורת הדין. כלומר, התערבות שיפוטית עלולה לפגוע בדיוק במה שמבקשים לעודד. זה טיעון נגד ההתערבות בלוין.
- **כוחו של הנרטיב:** אותן עובדות יכולות להיקרא כסיפור של "אישה חלשה, בעל חזק וילדים בתווך" (ולכן יש להגן עליה) או כ"בעל צדיק ונדיב מול אישה תובענית". סביר שהסיפור הראשון עמד בפני השופטים. עורך דין עובד בשני מישורים: המשפטי (כוונה, שפיטות, סעיפים) והנרטיבי (הסיפור האמיתי: מי החזק ומי החלש, מה ההקשר האנושי).

1.4 שומר סף שני: שפיטות

✦ הגדרה — שפיטות

גם כשהצדדים התכוונו לקשר משפטי, נשארת השאלה: האם נושא הסכסוך ראוי ומתאים להכרעה בבית המשפט? בית המשפט הוא מוסד ציבורי הממומן מכספי הציבור ובעל תפקיד חברתי-חינוכי, ולכן אין רצון שכל מחלוקת פרטית זניחה תגיע אליו. זו הכרעה של מדיניות משפטית הנתונה לשיקול דעת השופט.

נקודת המוצא: הסכמים הם שפיטים. יש אינטרס חברתי מובהק שהסכמים יקוימו. מכאן שהשפיטות היא הכלל, ושאלת אי-שפיטות מתעוררת רק בחריגים. ארבעה חריגים מרכזיים:

חריג	מהות	הרציונל / הסייגים
1. זוטי דברים	עניין פעוט, חסר משמעות מעשית (ויכוח על סדר כדורי הגלידה בגביע)	לא להעמיס על המערכת "שטויות". הגבול בין פעוט למהותי אינו חד, וכל מקרה לגופו.
2. הסכמים פרטיים ואינטימיים	הסכמים במרחב האישי המובהק: משפחה, זוגיות, חברות קרובה (הסכם על ההתנהלות היומיומית או חיי אישות, קנס על אי-הגעה ללימוד משותף)	שאלה של מדיניות ציבורית. סייג: הסכמים רכושיים מובהקים (הסכמי ממון, גירושין, כתובה) הם שפיטים.
3. הסכמים פוליטיים	הסכמים בין גופים פוליטיים בליבת הפעילות הפרלמנטרית (איך להצביע בכנסת)	הפרדת רשויות ושיקולים דמוקרטיים: זה מוכרע בקלפי. סייג: היבטים מנהליים/חלוקת תפקידים (מינויים בדירקטוריונים ציבוריים) – נכונות להתערב גוברת. כל הסכם פוליטי מדליק "נורת אזהרה".
4. סעיף 33 לחוק החוזים	חוזה למתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה לפי הכרעה/הערכה של צד או צד שלישי	בית המשפט לא יחליף את שיקול הדעת המקצועי של המכריע.

§ סעיף — סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי)

חוזה שלפיו יינתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה, על פי הכרעה או הערכה של אחד הצדדים או של אדם שלישי – אין ההכרעה או ההערכה לפי החוזה נושא לדיון בבית המשפט.

בניסוח פשוט: כשהוסכם מראש שגורם מקצועי (שופט בתחרות, ועדה, בוחן) מכריע – השופט לא יכנס לשאלה אם הציון היה גבוה או נמוך.

⚖ פסק דין — קרסניאנסקי (ע"א 338/65): חידון התנ"ך

משתתף בחידון התנ"ך למבוגרים ענה תשובה שלדעתו נכונה וקיבל עליה 6 נקודות במקום 10, ולכן סיים במקום השני. התקנון (שהוא חוזה) קבע שהשופטים מכריעים כמה נקודות לתת. בית המשפט: זה בדיוק המצב של סעיף 33 – ההכרעה אינה שפיטה. **שאלה שנותרה פתוחה:** טעות חשבונית של השופטים בסיכום הנקודות. הגישה המצמצמת: סעיף 33 חל על שיקול דעת מקצועי בלבד, וטעות טכנית ניתנת לתיקון. הגישה המרחיבה: כל מה שנוגע לציון, כולל טעות חשבונית, חסום. לא הוכרע בפסיקה.

1.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "אם כתוב במפורש שאין כוונה – אין חוזה" – **לא תמיד.** רוב המקרים כן, אך לוין נ' לוין הוכיחה שהצהרה מפורשת יכולה ליפול מול מבחני עזר ושיקולי שפיטות.
- "חוזה חייב להיות כתוב בלשון משפטית" – לא. לשון משפטית היא רק אינדיקציה.
- "בני משפחה לעולם לא כורתים חוזה" – לא. הסכמי ממון, גירושין וכתובה שפיטים. החריג נוגע רק לתחום ה"אפור" של הסכמות אינטימיות.
- "שומרי הסף נבדקים בזה אחר זה" – בפועל הם עובדים במקביל (לוין).
- "שפיטות היא חריג" – הפוך: השפיטות היא הכלל, ואי-השפיטות החריג.
- "כוונה נבחנת לפי מה שהיה בלב" – לא. נבחנת לפי מה שמשתקף החוצה (דברים שבלב אינם דברים).
- "שאלת כריתת החוזה ושאלת תום הלב הן אותה שאלה" – לא. הן נבדקות בנפרד.

1.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- חוק החוזים לא מגדיר "חוזה"; ההגדרה פסיקתית: **חוזה = הסכם משפטי**.
- שני שומרי סף: **כוונה ליצור יחסים משפטיים** (נבדקת לפי הביטוי המפורש, ואם אין – לפי נסיבות, שפה, יחסים ונושא) ו**שפיטות** (הכלל: שפיט; חריגים: זוטי דברים, פרטיים-אינטימיים, פוליטיים, סעיף 33).
- בקושי להכריע בכוונה – פונים לשפיטות ולמדיניות (**לוין נ׳ לוין**), ולכן עורך דין חייב לטעון בשני המישורים ולספר סיפור משכנע.
- אחרי שומרי הסף (וכשרות) נכנסים לקומה הראשונה: **כריתת חוזה** (גמירת דעת + מסוימות) ו**תום לב במשא ומתן** – שתי שאלות נפרדות.

פרק 2

העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

2.1 מבוא: שני התנאים לכריתת חוזה

אחרי ששני שומרי הסף נחצו (פרק 1), נכנסים לקומה הראשונה של הארמון. כדי שייכרת חוזה נדרשים שני תנאים מצטברים: **העדה על גמירת דעת** ו**מסוימות**. אפשר לדמיין ציר זמן: הצדדים נפגשים ומנהלים משא ומתן, מתקרבים זה לזה, ובנקודה שבה מתקיימים יחד גמירת הדעת והמסוימות – **נכרת החוזה**. כל עוד אחד מהם חסר, הצדדים עדיין "בתוך המשא ומתן".

! שים לב — כוונה משפטית אינה גמירת דעת

אלה שני מושגים שונים. בזיכרון דברים שבו כתוב שהמוכר מתחייב למכור והקונה לקנות, אבל גם "ניפגש בעוד שבוע ונסגור את המחיר", **יש** כוונה ליצור יחסים משפטיים (פרק 1) אבל **אין עדיין** גמירת דעת לגבי תנאי ההתקשרות. לכן לא בטוח שיש חוזה.

2.2 גמירת דעת והעדה עליה

✦ הגדרה — גמירת דעת

רצון מגובש והחלטי להתקשר בחוזה: לא התעניינות כללית אלא החלטה סופית וחד-משמעית – "כן, אני בפנים".

שתי שיטות בעולם

	מבחן סובייקטיבי (למשל צרפת)	מבחן אובייקטיבי (למשל אנגליה)
מה בודקים	הרצון הפנימי האמיתי של כל צד: האם בליבו באמת רצה את העסקה	ההתנהגות החיצונית: חתמת? שילמת? לחצת יד? מה אדם סביר היה מבין מהתנהגותך
ערך מוביל	אוטונומיה של הרצון הפרטי: "אם לא רציתי באמת – אי אפשר לכפות עליי חוזה"	הגנה על האחר ועל ודאות מסחרית: "אם גרמת לאחר להסתמך עליך – שא בתוצאות"

בחוק החוזים (1973) בחר המחוקק הישראלי בניסוח מדויק: לא נדרשת "גמירת דעת" אלא "העדה על גמירת דעת" – הגילוי החיצוני של הרצון (סעיף 2: הצעה היא פנייה "המעידה על גמירת דעתו" של המציע; סעיף 5: קיבול הוא הודעה "המעידה על גמירת דעתו" של הניצע). זו אימוץ של **המבחן האובייקטיבי**, בהשראת המשפט האנגלי.

✎ דוגמה — הקונה שמעמיד פנים

אדם מזמין שני חברים כעדים ומבהיר להם: "אני לא מעוניין בעסקה, אני רק שומר לעצמי אופציה". הוא עורך עם המוכר זיכרון דברים (מחיר סוכם, ביצוע בעוד שלושה ימים, מקדמה של 5,000 ש"ח), ובינתיים לוחש לחבריו "הכול משחק". כעבור יומיים הוא קונה רכב אחר ומודיע למוכר "אין עסקה". **במבחן סובייקטיבי** החברים יעידו שלא הייתה גמירת דעת פנימית, ולכן אין חוזה (אולי רק פיצוי בגין חוסר תום לב). **במבחן האובייקטיבי** בית המשפט יאמר "לא מעניין מה היה בליבך": חתימה ומקדמה מלמדות אדם סביר שרצית בעסקה – **יש חוזה**.

הרציונל: הסתמכות

✦ הגדרה — הסתמכות

ההנחה של צד להסכם שהתנהגותו של הצד השני משקפת את רצונו הפנימי. אני לא יודע מה מתחולל בליבו של הצד השני, אני רואה שהוא חותם, משלם או לוחץ יד ומניח שהוא עושה זאת כי הוא באמת מעוניין. המשפט מגן על הסתמכות זו, ולכן ברוב המכריע של המקרים הרצון הפנימי אינו מעלה ואינו מוריד: **יש התנהגות → יש הסתמכות → יש חוזה.**

! שים לב — זה לא טריק פורמלי

המבחן האובייקטיבי אינו אומר שכל חתימה או מקדמה יוצרת חוזה. בכל מקרה בית המשפט בוחן את **מכלול ההתנהגות** בנסיבות הספציפיות ושואל: האם אדם סביר, המסתכל על התמונה המלאה, היה מבין שיש כאן רצון מגובש והחלטי לעסקה? לכן אותה פעולה יכולה להיות העדה על גמירת דעת במקרה אחד ולא באחר.

✎ דוגמה — פרשת האימוג'י (קנדה)

מוכר נהג לשלוח לקונה טיוטת חוזה בקובץ וורד, והקונה היה עונה "קראתי, אני מאשר", ואז העסקה בוצעה. בסבב מסוים ענה הקונה בלבד באימוג'י של אגודל, ואחר כך התחרט: "זה רק אימוג'י". בית המשפט קבע שבנסיבות הספציפיות זו העדה על גמירת דעת, כי בפעמים הקודמות האישור המילולי שימש אות לסגירת עסקה, והאגודל מילא את אותו תפקיד. אין חובה לזכור את הפסק, אלא להבין את הרעיון. **סייג:** ב-99% מהמקרים אימוג'י לבדו לא ייחשב העדה על גמירת דעת; הכול תלוי בהקשר.

⚖ פסק דין — עדני נ' דוד (ע"א 7193/08)

דוגמה קלאסית לכך שהשופטים אינם מתעניינים ברצון הפנימי אלא בהתנהגות החיצונית ובמה שאדם סביר היה מבין ממנה. (על מסוימות בפסק זה ראו פרק 3.)

2.3 החריג הראשון: היעדר הסתמכות

הכלל האובייקטיבי נשען על הסתמכות. מכאן ההיגיון של החריג: אם הצד השני יודע (או היה צריך לדעת) שההתנהגות החיצונית אינה משקפת רצון פנימי אמיתי – אין הסתמכות, ולכן אין העדה על גמירת דעת, ואין חוזה. מי ש"תפס" אדם שיכור, חולה או מבולבל לא יכול להיתמם ולומר "אבל הוא חתם".

⚖ פסק דין — פרץ בונה הנגב נ׳ בוחבוט (ע״א 1932/90) – דעת המיעוט של השופט שמגר

בוחבוט האב, בעל נטייה לשתייה, רשום בטאבו כבעלים של דירה שבה גר בנו. חברת יזמות שפגשה קודם את הבן תכננה בכוונה לפגוש את האב בלי הבן, ידעה שאינו צלול, הציגה חוזה מוכן והוסיפה "מעטפה" מחוץ לחוזה; האב חתם ולקח כסף. המחוזי: יש חוזה (מבחן אובייקטיבי: חתם ולקח כסף), אך לא נתן צו פינוי נגד הבן. בעליון לא ערערו על עצם החוזה, והרוב לא נכנס לכך. **השופט שמגר (מיעוט)** ניצל את המקרה להגדרת הדוקטרינה: המבחן האובייקטיבי חל רק כשיש הסתמכות; החברה ידעה שהחתימה אינה משקפת רצון אמיתי, ולכן אין הסתמכות ואין חוזה. הרעיון הפך אחר כך להלכה.

⚖ פסק דין — ברשי נ׳ עיזבון המנוח זלמן ברשי (ע״א 3601/96)

זלמן ברשי, אדם מבוגר בבית חולים סיעודי במצב "שכלי בלבולי" (צלול בחלק מהשעות), לא הוכרז פסול דין. בן ונכד הוציאו אותו לטיול ברכב עם עורך דין ועם חוזה מוכן, ובמהלך פיקניק (גרעינים ושתייה) חתם על מתנת כל מניותיו בחברת נדל״ן. שלושה חודשים אחרי מותו הציגו את החוזה. בית המשפט: החתימה אכן שלו, אך **אין הסתמכות**: הם ידעו על מצבו, החתימו ברכב ולא במשרד, בלי רופא שיצהיר שהוא צלול ובלי זמן לחשוב או להתייעץ. כלומר ידעו שהתנהגותו אינה משקפת רצון אמיתי. אין העדה תקפה, אין חוזה. כאן אימצו **כל** השופטים פה אחד את דוקטרינת העדר ההסתמכות.

2.4 החריג השני: "לא נעשה דבר" (Non Est Factum)

זהו חריג שונה, נדיר וקיצוני יותר. כאן יש **הסתמכות לגיטימית** (החברה לא ידעה כלום), ובכל זאת בית המשפט מוכן לקבוע שהפעולה המשפטית כאילו לא נעשתה כלל. זו אינה עילת ביטול אלא **אפסות**: לא חוזה שניתן לבטל, אלא היעדר כריתה מלכתחילה. הדוקטרינה יובאה מהמשפט האנגלי.

⚖ פסק דין — הדר חברה לביטוח נ׳ פלוני (ע״א 8163/05)

זוג צעיר, דירה רשומה על שם הבעל. הבעל לווה מחברת ביטוח בשעבוד הדירה, והחברה (שלמדה מפרשת פרץ) דרשה גם התחייבות של האישה לפנות את הדירה בעת הצורך, והיא חתמה במשרד. כעבור שנים הבעל הפסיק לשלם ונעלם. התברר שלאישה היסטוריה מתועדת של מחלת נפש ותלות קיצונית בבעלה; היא התנגדה, אך הבעל איים שיעזוב, והיא חתמה מפחד משתק. **למה הכלים הרגילים לא עזרו?** (1) אין כשרות פגומה, היא לא הוכרזה פסולת דין; (2) אין "העדר הסתמכות", לחברה הייתה הסתמכות לגיטימית; (3) כפייה לפי סעיף 17 אינה רלוונטית, כי הסעיף דורש כפייה מצד הצד השני לחוזה והמאיים כאן הוא צד שלישי (הבעל). בית המשפט יבא את "לא נעשה דבר" וקבע: ביחסים בינה לבין החברה התחייבות הפינוי אינה חוזה.

§ סעיף — שני תנאים מצטברים להפעלת "לא נעשה דבר"

- **תנאי ראייתי חזק במיוחד:** ודאות קרובה ל-100% (ולא 51% כמקובל באזרחי), באמצעות ראיות מוצקות כמו תיעוד רפואי ונסיבות ברורות.
- **שיקולי צדק קיצוניים:** מקרה ש"זועק לשמיים" ולא ניתן מטעמי צדק לקבוע שנכרת חוזה.

הנימוק החלוקתי: שני צדדים תמימים (האישה, חולה וקורבן; חברת הביטוח, שפעלה בתום לב) והצד ה"אשם" (הבעל) נעלם. השאלה היא למי קל יותר לשאת בנזק. חברת הביטוח נשארת עם ההתחייבות מול הבעל ועם השעבוד ויכולה לפעול נגדו אם יימצא, ואילו האישה הייתה מושלכת לרחוב. העליון הדגיש שהחריג נדיר ושמאז 2007 כמעט לא התקבלו טענות כאלה.

	היעדר הסתמכות	"לא נעשה דבר"
הסתמכות של הצד השני	אין: הוא ידע או היה צריך לדעת	יש: הסתמכות לגיטימית, לא ידע דבר
הנימוק	המבחן האובייקטיבי חל רק כשיש הסתמכות	חריג סובייקטיבי נדיר: כאילו הפעולה לא נעשתה
תנאים	ידיעה/היה צריך לדעת שההתנהגות אינה משקפת רצון	ראיה כמעט ודאית + צדק קיצוני
פרשות	פרץ בונה הנגב (מיעוט שמגר), ברשי	הדר חברה לביטוח נ׳ פלוני

★ טיפ למבחן — מתי לטעון איזה חריג

בשאלה על אדם שחתם כשאינו צלול או הוחתם בתחבולות, בדקו קודם: **האם הצד השני ידע?** אם כן – היעדר הסתמכות. אם הצד השני תמים לחלוטין והנפגע במצב קיצוני (כפייה/הטעיה חמורה שאין עילה לפי פרק ב׳) – "לא נעשה דבר", ורק אם יש ראיות כמעט ודאיות וצדק זועק. כל חריג מהם הוא נדיר.

2.5 הקשר לפרק ב׳ (ביטול בשל פגמים)

בפרק ב׳ לחוק החוזים (נלמד בפרק 8) המחוקק מספק למי שלא באמת רצה את החוזה עילות ביטול ספציפיות (טעות, הטעיה, כפייה, עושק). שני החריגים שלמדנו כאן הם מקרים ש"אמורים היו" לשבת בפרק ב׳, אבל הנפגע לא עמד בתנאי הסעיפים, ולכן הפסיקה מצאה פתרון באזור התפר. ההבדל: בפרק ב׳ יש **חוזה ניתן לביטול**; כאן **אין חוזה כלל**.

2.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "גמירת דעת היא מה שהיה בלב" – לא. נדרשת **העדה** על גמירת דעת (גילוי חיצוני), לפי מבחן אובייקטיבי.
- "חתימה = חוזה" – לא בהכרח. המבחן בוחן את מכלול הנסיבות. וחתימה בלי הסתמכות (הצד השני ידע שאינו צלול) אינה יוצרת חוזה.
- "היעדר הסתמכות ו"לא נעשה דבר" זה אותו דבר" – לא. בראשון הצד השני ידע; בשני הוא תמים.
- "לא נעשה דבר" אינה עילת ביטול – זו אפסות: אין חוזה כלל.
- "אדם שאינו צלול תמיד יכול לבטל" – לא. נדרשת הוכחה: ידיעה של הצד השני (היעדר הסתמכות) או ראיות כמעט ודאיות וצדק קיצוני ("לא נעשה דבר"), ולא הכרזה כפסול דין.
- "רצון פנימי תמיד לא רלוונטי" – ברוב המקרים נכון, אך יש שני חריגים שבהם מתחשבים בו.
- לבלבל בין **כוונה ליצור יחסים משפטיים** (שומר סף, פרק 1) לבין **גמירת דעת** (תנאי כריתה).

2.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- כריתת חוזה = העדה על גמירת דעת + מסוימות, באותה נקודת זמן.
- המבחן להעדה הוא **אובייקטיבי** (מה אדם סביר מבין מההתנהגות), בהשראת המשפט האנגלי, ונשען על עקרון **ההסתמכות** והוודאות המסחרית.
- חריג א׳ – **היעדר הסתמכות**: אם הצד השני יודע שההתנהגות אינה משקפת רצון, אין חוזה (פרץ בונה הנגב – מיעוט שמגר; ברשי – פה אחד).
- חריג ב׳ – **"לא נעשה דבר"**: נדיר; ראיה כמעט ודאית + צדק קיצוני; אפסות ולא ביטול (הדר).
- ברוב המכריע של המקרים הרצון הפנימי אינו משחק תפקיד.

פרק 3

מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

3.1 מבוא: התנאי השני לכריתה

התנאי השני לכריתת חוזה הוא **מסוימות**. המחוקק חסך במילים: בחוק החוזים (חלק כללי) מופיעה המילה "מסוימות" (בהגדרת ההצעה, סעיף 2) ללא הגדרה מפורטת, ובית המשפט הוא שמילא אותה בתוכן. הרעיון: הצדדים צריכים לסכם את הפרטים החשובים של העסקה. אין חובה לסכם הכול, אלא רק את המהותי.

מכאן שתי שאלות, וכל הפרק עוסק בהן:

1. **איך יודעים מהו פרט חשוב?** בחוזה מכר דירה, חוזה עבודה, חוזה זיכיון או זיכרון דברים בין בני זוג חשובים דברים שונים.
2. **מה עושים עם פרטים לא חשובים שלא סוכמו?** האם חוסר הסכמה על הובלה, משלוח, אריזה או ביטוח מפיל את החוזה, או שמשלימים אותם בדרך אחרת?

✎ דוגמה — עסקת הפסנתר

שני צדדים הסכימו על מכירת פסנתר מסוים: זהות הצדדים, הנכס, המחיר ומועדי התשלום. אחרי התשלום שואל הקונה "מתי תשלח לי את הפסנתר?" והמוכר עונה "למה שאשלח? תבוא לקחת". אם האחריות להובלה היא **פרט מהותי** – משלא סוכמה, אין מסוימות ואין חוזה. אם היא **פרט משני** – יש חוזה, והחסר מושלם (לפי נוהג, דין דיספוזיטיבי וכו׳).

3.2 הצעת "טופס המסוימות" של השופט עציוני – ולמה נדחתה

⚖ פסק דין — קפולסקי נ׳ גני גולן (ע"א 649/73)

בעניין זיכרון דברים למכירת מגרש קבע בית המשפט שלא נכרת חוזה בשל היעדר מסוימות. בסוף הפסק העלה השופט עציוני רעיון: ליצור **"טופס אחיד"** – רשימה קבועה של פרטים שהם תנאי סף. **אם כל הפרטים בטופס מולאו – יש חוזה; אם חסר פרט – אין.** הרשימה המוצעת: שמות הצדדים, מהות הנכס (גוש, חלקה), מהות העסקה (מכר, שכירות, מתנה), המחיר, מועדי התשלום, ומי נושא בהוצאות ובמסים. היתרון: ודאות, ועורך דין יכול לענות ללקוח תוך חמש דקות. הפסיקה לא קיבלה את ההצעה.

למה הפסיקה דחתה את "רשימת הברזל"? סיפור הדירה

✎ דוגמה — תרגיל מס

מכירת דירה ב-2,500,000 ₪. המוכר מבקש "תרגיל מס": הקונה משלם כעת 2,250,000 ₪, והשאר (250,000 ₪) ייחשבו הלוואה מהמוכר, בלי ריבית, הצמדה או מועד פירעון ("כשהמסים שלי יסתדרו"). הם כותבים מסמך פרטי ולא מדווחים. הקונה משלם, מקבל מפתח וגר בדירה שמונה שנים. אז המוכר מודיע: "העלמת המס הסתדרה, תשלם את ה-250,000 ₪". הקונה: "אני לא חולק על שום פרט, תן לי 3–4 חודשים להתארגן". המוכר: "אם אתה חולק על מועד התשלום – אין חוזה, צא מהדירה". לפי טופס עציוני: מועדי תשלום חסרים לגבי ה-250,000 ₪ → "אין חוזה". אבל כולנו מרגישים שיש חוזה: שולמו 90% מהמחיר, נמסרה חזקה, עברו שמונה שנים – **גמירת דעת ברמה הכי גבוהה**. ברגע שאנו בטוחים שהצדדים רצו את העסקה ב-100%, כל מה שלא סוכם נראה לנו "לא כזה נורא". וזה כל סיפור המסוימות.

! שים לב — הניתוק בין שני התנאים

עציוני יוצר ניתוק מוחלט בין גמירת דעת למסוימות: גם אם ברור ב-100% שהצדדים רצו, חסר פרט ברשימה = אין חוזה. הפסיקה דחתה זאת: אי אפשר לנתק. אכן יש שני תנאים, אך יש ביניהם יחסי כוחות: העדה על גמירת דעת היא "המלך", והמסוימות היא תנאי משני, גם דרישה פורמלית וגם אינדיקציה לרצון המגובש. ככל שסוכמו יותר פרטים – מתחזקת המסקנה שהייתה גמירת דעת; ככל שחסרים פרטים מהותיים – היא נחלשת.

3.3 מהו "פרט מהותי"?

✦ הגדרה — פרט מהותי

פרט שכל עוד הצדדים לא סיכמו אותו – לא ניתן להאמין שהיה להם רצון מגובש לעסקה. או: פרט שבלעדיו אין העדה על גמירת דעת.

בכל תיק שבו יש ויכוח על מסוימות הדיון נראה אותו דבר:

מי טוען	הטיעון הטיפוסי
"נכרת חוזה"	הנה כל הפרטים שסיכמנו. ראו כיצד התנהגנו, מה שילמנו ועל מה חתמנו: היה לנו רצון מגובש. אולי חסרים כמה פרטים, אך הם אינם מונעים להסיק גמירת דעת. "סיכמנו מספיק פרטים".
"לא נכרת חוזה"	יש פרטים שלא סיכמנו, ובדיוק כל עוד הם חסרים אדם סביר אינו יכול להבין מהתנהגותנו שהייתה גמירת דעת. הפרטים החסרים הם מהותיים.

⚖ פסק דין — עדני נ׳ דוד (ע"א 7193/08)

שני אנשי עסקים ערכו, בעזרת עורך דין, זיכרון דברים למכירת חנות (כולל סעיף חרטה אם לא יימצא שוכר). לא נחתם חוזה מפורט, ומועדי התשלום, שנקבע שיפורטו בנספח, לא נכתבו כי הנספח לא נערך. **רוב (שני שופטים):** הצדדים המשיכו לנהל משא ומתן והתכתבו על מועדי התשלום ולא הגיעו להסכמה, ולכן כל עוד לא סוכמו – לא התגבשה גמירת דעת. מועדי התשלום הם פרט מהותי ואין חוזה. **מיעוט (השופט עמית):** המחלוקת לא נסבה על עצם מועדי התשלום אלא על שאלה טכנית (לאן יופנה הכסף קודם), ומהמסמך, החתימות וההתנהגות הכוללת הוא השתכנע שהייתה גמירת דעת. מועדי התשלום אינם מהותיים וניתן להשלימם. **כולם פועלים באותה מתודולוגיה** ("האם חיסרון הפרט מונע מסקנה שהייתה העדה על גמירת דעת?"); ההבדל ביישום ובשיקול הדעת השיפוטי.

★ טיפ למבחן — אין רשימה קבועה

כותרת עיתונאית כמו "אין מועדי תשלום – אין חוזה" מטעה. *בעדני* מועדי התשלום היו מהותיים; בסיפור הדירה לא. אין פרט שהוא תמיד חשוב ואין פרט שהוא תמיד לא חשוב. הכול תלוי בהתנהגות הצדדים ובנסיבות. המטרה: לוודא שסוכמו מספיק פרטים להסקת גמירת דעת ושלא חסר פרט שמונע זאת.

3.4 השאלה השנייה: איך משלימים פרטים לא חשובים?

פרט שאינו מהותי ולא סוכם – החוזה נכרת, והחסר מושלם באחד משלושה מנגנונים:

מנגנון א׳: סעיף 26 לחוק החוזים – נוהג

§ סעיף — סעיף 26 – פרטים שלא נקבעו

פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יושלמו לפי מדרג: (1) **הנוהג הקיים בין הצדדים**; (2) בהיעדרו – **הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג**.

- **נוהג בין הצדדים:** אם זו לא העסקה הראשונה, ובעבר נהגו בדרך מסוימת (הקונה דאג תמיד להובלה) והפעם לא דנו בכך – משלימים לפי הנוהג ביניהם. הרציונל: אם בעבר נהגנו כך ובהווה שתקנו, "ברור לנו" שנמשיך.
- **נוהג מקובל בשוק:** דמי תיווך בשכירות לשנה = שווי חודש שכירות; דמי תיווך בקניית דירה לרוב 1%–2% מהמחיר.
- **הבעיה:** ברוב העסקאות אין נוהג ברור, לא בין הצדדים ולא בשוק. המנגנון מצוין כשיש נוהג, ולעיתים קרובות פשוט אינו רלוונטי.

מנגנון ב׳: הוראות דיספוזיטיביות

סוג הוראה	משמעות	דוגמה
קוגנטית (כופה)	אי אפשר להתנות עליה גם אם הצדדים רוצים	חוק השכירות והשאילה: דירת מגורים חייבת להיות ראויה למגורים; אי אפשר לוותר

דיספוזיטיבית (מרשה)	"מודל ברירת מחדל": אתם חופשיים לסכם, ואם לא סיכמתם זה ההסדר שיחול – מנגנון השלמה	סעיף 46 לחוק החוזים: השלמת מחיר לפי מחיר מקובל, הערכת שמאי וכדומה

! שים לב — סעיף 46 כמעט לא בשימוש

בית המשפט כמעט ואינו משתמש בסעיף 46, כי ברוב המכריע של המקרים המחיר הוא פרט מהותי. אם המחיר לא סוכם – בדרך כלל אין העדה על גמירת דעת, אין חוזה, ואי אפשר לעבור לשלב ההשלמה. **הכלל:** מנגנוני השלמה משמשים אך ורק להשלמת פרטים **לא מהותיים**. אם הפרט החסר מהותי – אין חוזה ולא משלימים.

מנגנון ג׳: ביצוע מיטבי (אג׳מי נ׳ נווה שלום, ע"א 1456/22)

כלי פסיקתי: מי שטוען שנכרת חוזה נותן לצד השני לבחור את הדרך הנוחה לו להשלמת הפרט החסר. בהשראת *עדני*: המוכר טוען שמועדי התשלום חשובים ובכל זאת טוען שיש חוזה – תן לקונה לבחור את המועד הנוח לו. והקונה, שטוען שהפרט אינו חשוב, לא אמור להתנגד שייקבע לטובת הצד השני. מנגנון אלגנטי, אך בפועל כמעט לא נזקקים לו: ברגע שנקבע שיש חוזה, ב-99% מהמקרים הצדדים מסתדרים ביניהם.

3.5 טכניקות לכריתת חוזה: הצעה וקיבול מול זיכרון דברים

סעיף 1 לחוק החוזים קובע שחוזה נכרת בדרך של **הצעה וקיבול**. סעיף 2 מגדיר **הצעה** כפנייה המעידה על גמירת דעת של המציע ו**מסוימת דיה** (כלומר ההגדרה כבר מכילה את שני התנאים), וסעיף 5 מגדיר **קיבול** כהודעה המעידה על גמירת דעתו של הניצע. המפגש בין הצעה לקיבול הוא הנקודה שבה מתקיימים העדה על גמירת דעת של שני הצדדים ומסוימות.

	הצעה וקיבול ("דרך המלך")	זיכרון דברים / מפגש משותף
מתי	הצדדים אינם מגיעים להסכמה באותו זמן: אחד שולח הצעה, השני עונה בקיבול	הצדדים יושבים יחד ומגיעים להסכמה באותו מעמד
מי המציע	חשוב: מי "מציע" ומי "ניצע"	לא משנה: "קיצור דרך" – בודקים ישירות האם יש גמירת דעת ומסוימות
הכללים	סעיפים 2–11: חזרה מהצעה, פטירת המציע, איחור בתשובה וכו׳ (פרק 4)	אין צורך בכללי ההצעה והקיבול
פסקי דין	ראו פרק 4	עדני נ׳ דוד, אג׳מי נ׳ נווה שלום, רבינאי (ע"א 158/77)

3.6 שלד לפתרון שאלה על כריתה

1. **שומרי סף:** כוונה ליצור יחסים משפטיים, שפיטות, כשרות (פרק 1).
2. **גמירת דעת:** האם יש התנהגות חיצונית המעידה על רצון מגובש (חתימה, תשלום, מסירה, ברכה)? האם יש חריג (היעדר הסתמכות / לא נעשה דבר)?
3. **מסוימות:** אילו פרטים סוכמו ואילו חסרים? **האם הפרט החסר מהותי** – כלומר, האם בלעדיו אדם סביר אינו יכול להסיק גמירת דעת? טענו לכל צד.
4. **אם הפרט לא מהותי:** השלמה: סעיף 26 (נוהג), הוראה דיספוזיטיבית, ביצוע מיטבי.

5. **טכניקה:** האם זו הצעה וקיבול (סעיפים 2–11) או זיכרון דברים (בדיקה ישירה)?
6. **צורה:** האם נדרש כתב (מקרקעין, סעיף 8 – פרק 7)?
7. **במקביל:** שאלת תום הלב במשא ומתן (פרקים 5–6) – שאלה נפרדת.

3.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "מועדי תשלום חסרים = אין חוזה" – **לא**. אין פרט שהוא תמיד מהותי (*עדני* מול סיפור הדירה).
- "יש רשימה סגורה של פרטים מהותיים" – לא. הצעת עציוני נדחתה.
- "אפשר להשלים כל פרט חסר" – לא. השלמה רק לפרטים לא מהותיים; פרט מהותי חסר = אין חוזה.
- "סעיף 46 משלים את המחיר" – תיאורטית כן, אבל המחיר כמעט תמיד מהותי ולכן בפועל אין שימוש.
- "מסוימות וגמירת דעת הם תנאים נפרדים לחלוטין" – לא. המסוימות היא גם אינדיקציה לגמירת דעת.
- לבלבל בין **הוראה קוגנטית** (אי אפשר להתנות) לבין **דיספוזיטיבית** (ברירת מחדל).
- בזיכרון דברים לא צריך לחפש "מי המציע" – בודקים ישירות גמירת דעת ומסוימות.

3.8 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- מסוימות = הצדדים סיכמו את הפרטים **המהותיים** (לא הכול).
- **פרט מהותי** = פרט שכל עוד הוא חסר לא ניתן להאמין שהייתה גמירת דעת. אין רשימה ואין טופס (קפולסקי: עציוני נדחה). גמירת הדעת היא "המלך".
- **עדני נ׳ דוד:** הרוב – מועדי התשלום מהותיים, אין חוזה; המיעוט – אינם מהותיים. אותה מתודולוגיה, יישום שונה.
- השלמת פרט לא מהותי: סעיף 26 (נוהג בין הצדדים, ואז נוהג מקובל) → הוראה דיספוזיטיבית (למשל סעיף 46) → ביצוע מיטבי (אג׳מי).
- שתי טכניקות כריתה: הצעה וקיבול (סעיפים 2–11) וזיכרון דברים (בדיקה ישירה).

פרק 4

הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

4.1 מתי בכלל משתמשים בכללי הצעה וקיבול

חוזה נכרת כשיש העדה על גמירת דעת של שני הצדדים ומסוימות. החוק (סעיפים 2–11) מארגן זאת בשני מושגים: **הצעה** ו**קיבול**. נקודת המפגש ביניהם היא הרגע שבו מתקיימות שתי גמירות הדעת והמסוימות.

	הצעה וקיבול (קלאסית)	זיכרון דברים / מפגש משותף
איך זה נראה	צד אחד פונה ("הצעה"), הצד השני עונה אחר כך ("קיבול") בזמנים שונים	הצדדים יושבים יחד ומגיעים להסכמה באותו מעמד
גמירת דעת	של המציע קודמת לזו של הניצע	משותפת, באותו רגע
מה בודקים	כללי סעיפים 2–11: חזרה, פקיעה, איחור, פטירה, הסתייגות...	"קיצור דרך": ישר גמירת דעת + מסוימות (עדני נ׳ דוד, אג׳מי)
חיסרון	בין ההצעה לקיבול "יכול לקרות הכול"	שם "זיכרון דברים" אינו מונח משפטי – חשוב התוכן

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

קודם שואלים **איזו טכניקה** הייתה. אם הצדדים ישבו יחד וחתמו על מסמך – אין טעם לחפש "מי המציע"; בודקים ישר גמירת דעת ומסוימות. רק כשיש פער זמן בין הפנייה לתשובה נכנסים לסעיפים 2–11.

4.2 הצעה: הגדרה ושלושה בחינות

✦ הגדרה — הצעה (סעיף 2)

פנייה המעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר בחוזה ומסוימת דיה כדי שאפשר יהיה לכרות את החוזה בקיבול. כלומר, **ההגדרה כבר מכילה את שני התנאים**: גמירת דעת + מסוימות.

- **הצעה לעומת "הזמנה להיכנס למשא ומתן":** פנייה שאינה מעידה על גמירת דעת סופית (למשל "אני מוכן לשמוע הצעות", מודעה כללית) אינה הצעה; היא הזמנה לנהל משא ומתן. הקריטריון: האם *הצופה מבחוץ* היה מסיק רצון מגובש?
- **הצעה לציבור:** יכולה להיות הצעה אם היא מעידה על גמירת דעת ומסוימת (כגון מבצע מוגבל בזמן ובכמות); ההבחנה נעשית לפי תוכן הפנייה, לא לפי הכותרת.
- **מכרזים:** פרסום המכרז הוא בדרך כלל הזמנה להציע הצעות; ההצעות של המשתתפים הן ה"הצעות"; החוזה נכרת רק בקיבול של המזמין (בית יולס; ראו פרק 5).

4.3 חזרה מההצעה ופקיעתה

מצב	הדין
חזרה לפני מסירת ההצעה	המציע רשאי לחזור בו אם הודעת החזרה הגיעה לניצע לפני ההצעה או בעת מסירתה (סעיף 3)
הצעה "ללא חזרה" או שנקבע מועד לקיבול	אחרי שההצעה נמסרה לניצע – אסור לחזור בה (סעיף 3(ב)). החזרה אינה אפקטיבית
הצעה רגילה (בלי קביעה כזו)	המציע יכול לחזור בו כל עוד הניצע לא קיבל, בהודעה שהגיעה לניצע
פקיעה	ההצעה פוקעת כשעובר מועד הקיבול, כשהניצע דוחה אותה (סעיף 4), או בנסיבות נוספות שקבע החוק (למשל פטירה/אי-כשרות של המציע בנסיבות מסוימות)

! שים לב — שים לב: "הגיעה" ולא "נשלחה"

הודעות לפי החוק (חזרה, קיבול) נבחנות לפי **הגעתן לנמען** ולא לפי מועד שליחתן. חזרה שנשלחה בעל פה/בדואר אך הגיעה אחרי שהניצע כבר קיבל – אינה מועילה.

✎ דוגמה — דוגמה: מבצע הגיטרה

יובל מציע לדוד גיטרה במחיר מיוחד עד סוף החודש. דוד מתלבט, יוצא מהחנות – **אין קיבול** (הוא עדיין לא הודיע על גמירת דעת), וגם **אין דחיה** של ההצעה. בסוף החודש מתקשר דוד ומודיע ש"החליט סופית" לרכוש. הפנייה בתוך המועד; מסוימות – "לפי ההצעה"; השאלה היא רק גמירת הדעת. ש"החליט בליבו" קודם אינו מספיק (מבחן אובייקטיבי), אך ההודעה בטלפון מעידה על גמירת דעת – **יש קיבול וחוזה**.

4.4 קיבול

✦ הגדרה — קיבול (סעיף 5)

הודעה המעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר בחוזה לפי ההצעה. בקיבול **לא נדרשת מסוימות נפרדת**: הוא מתייחס למסוימות שהציג המציע.

- **בהתנהגות:** קיבול יכול להיעשות גם במעשה (אם ההצעה או הנוהג מאפשרים), לא רק בהודעה מפורשת.
- **מתי:** בתוך התקופה שנקבעה בהצעה, ובאין תקופה – בתוך זמן סביר (סעיף 8). קיבול באיחור אינו קיבול – לכל היותר הצעה חדשה.
- **שתיקה:** ככלל שתיקה אינה קיבול; חריג כשהצדדים קבעו כך מראש בהסכם או שיש נוהג בין הצדדים.
- **קיבול עם שינוי/הסתייגות:** אינו קיבול אלא **דחיית ההצעה והצעה נגדית**. הניצע שהסתייג איבד את ההצעה המקורית (הוא דחה אותה).
- **אופן ההודעה:** בכל דרך מקובלת בנסיבות, אלא אם נדרשה צורה בהצעה או בחוק (למשל מכתב רשום שהוסכם עליו).

4.5 שלד לפתרון שאלה

1. **טכניקה:** מפגש משותף (גמירת דעת + מסוימות) או הצעה וקיבול (סעיפים 2–11)?
2. **הצעה:** האם הפנייה מעידה על גמירת דעת ומסוימת, או רק הזמנה למו"מ?
3. **חזרה:** האם המציע חזר בו, ומתי הגיעה ההודעה לניצע; האם ההצעה "ללא חזרה" או עם מועד קיבול?
4. **פקיעה:** האם עבר המועד, האם הניצע דחה (כולל הסתייגות)?
5. **קיבול:** גמירת דעת של הניצע, בזמן, בדרך המתאימה; שתיקה/התנהגות?
6. **תום לב:** אם לא נכרת חוזה – האם יש הפרת סעיף 12 (פרקים 5–6)?

4.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "כל פנייה היא הצעה" – לא. נדרשים גמירת דעת ומסוימות; אחרת זו הזמנה למשא ומתן.
- "שליחת החזרה מספיקה" – לא. ההודעה צריכה להגיע לנמען בזמן.
- "הצעה עם מועד קיבול אפשר לבטל בכל עת" – לא. נקבע מועד = אין חזרה אחרי שנמסרה.
- "שתיקה היא הסכמה" – ככלל לא.
- "קיבול עם שינוי הוא קיבול" – לא. זו הצעה נגדית, וההצעה המקורית נדחתה.
- "בקיבול צריך מסוימות" – לא. המסוימות היא של ההצעה.

4.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- הצעה = פנייה המעידה על גמירת דעת + מסוימת; קיבול = הודעה על גמירת דעת לפי ההצעה.
- שתי טכניקות: הצעה וקיבול (סעיפים 2–11) או מפגש משותף (בודקים ישר גמירת דעת + מסוימות).
- חזרה מההצעה – רק אם הגיעה לפני/בעת ההצעה; הצעה "ללא חזרה" או עם מועד – מחייבת.
- ההצעה פוקעת בדחיה (כולל הסתייגות) ובעבור המועד; קיבול באיחור אינו קיבול.
- שתיקה אינה קיבול ככלל; הכול נבחן בצופה אובייקטיבי.

פרק 5

תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

5.1 מבוא: מהפכת 1973 – מתחרות לשותפות

עד 1973 (לפני חוק החוזים) נתפס המשא ומתן כ**תחרות**, אף כמלחמה: הצדדים הם יריבים. מי שאמר "לא ידעתי, לא סיפרו לי" קיבל תשובה: "הגעת לקרב – עליך לשאול, לבדוק ולהגיע מוכן". כל צד דאג רק לאינטרס שלו. עם חקיקת חוק החוזים ב-1973, בהשפעת המשפט הקונטיננטלי (בעיקר הגרמני), נכנס לחוק המונח "תום לב" – ומשמעותו שינוי תפיסתי: הצדדים הם **שותפים** (לפחות מיזם משותף). כל צד דואג לענייננו, אך בד בבד מודע לצד השני ולעיתים מתחשב באינטרס שלו. סעיף 12 נועד להחדיר להליך המשא ומתן נורמות של הגינות, מוסר וצדק.

§ סעיף — סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי)

- **12(א):** במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
- **12(ב):** צד שלא נהג בדרך כזאת חייב לצד השני פיצויים בשל הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה (הנוסח המדויק – בספר החוקים).

! שים לב — שתי שאלות נפרדות

כריתת חוזה (פרקים 2–4) ותום לב במשא ומתן הן שאלות עצמאיות. ייתכן חוזה בין שני רמאים, וייתכנו אנשים הגונים שלא כרתו חוזה. גם כשנכרת חוזה, ייתכן חוסר תום לב במשא ומתן (ראו פרק 6 – נטע מור).

5.2 המבחן לתום לב: סובייקטיבי או אובייקטיבי?

החוק אינו מסביר מהו תום לב; בית המשפט הוא שמילא את המונח. שתי גישות: **סובייקטיבית** – "תום לב" = להיות שלם עם הלב: מי שבטוח באמת ובתמים שהתנהגותו ראויה, נהג בתום לב ("פעולה המונחית על ידי שכנוע פנימי ואמונה של הפועל בהגינותה של פעולתו"); **אובייקטיבית** – אי אפשר לבחון כל אדם לפי קנה מידה אחר (לא ייתכן ששני אנשים ינהגו אותו דבר ולאחד ייסורי מצפון ולשני לא והתוצאה תשתנה), ולכן מבחן חברתי ורף אחיד: ההתנהגות צריכה לעלות בקנה אחד עם ערכי החברה.

✔ שורה תחתונה — ההכרעה בפסיקה

תום לב הוא מבחן אובייקטיבי. עולם הערכים האישי של הפרט אינו רלוונטי; השאלה היא מה החברה מצפה מאדם סביר. אין זה משנה אם האדם משוכנע שהוא "צדיק". (ההקבלה בבראשית: אבימלך "בתום לבבי ובניקיון כפי", ו"ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת" – ללא ניקיון הכפיים.)

"בדרך מקובלת ובתום לב": היו שופטים שביקשו להפריד: "דרך מקובלת" = המבחן האובייקטיבי ו"תום לב" = הסובייקטיבי. הגישה לא התקבלה. בפועל "דרך מקובלת" נבלעה תחת "תום לב" האובייקטיבי. ולעיתים מדברים על "ממד סובייקטיבי": אין זה שינוי המבחן, אלא שיישום ערכי החברה מושפע מהנסיבות ומטיב היחסים בין הצדדים.

השאלה הקשה מתעוררת במה שהם "ערכי החברה" – מושג דינמי שהכרעה בו עשויה להיות קשה מאוד.

5.3 צורות של חוסר תום לב במשא ומתן

א. אי-גילוי

הכלל: במקום שערכי החברה מחייבים גילוי מידע, צד שאינו מגלה אותו נוהג בחוסר תום לב. יש "מקרים קלים" ו"מקרים קשים".

⚖ פסק דין — ספקטור נ׳ צרפתי (ע״א 838/75) – מקרה קשה

שני מגרשים צמודים וזהים. על האחד בונה הקבלן צרפתי בניין של 16 דירות. ספקטור מבקש למכור את המגרש השני. מתווך גילה בעירייה שמתוכננת הפקעה חלקית לצורך כביש, ובעקבותיה ניתן לבנות רק 12 דירות. ספקטור סירב להוריד מחיר והמתווך התפטר. מתווך אחר הציג את המגרש לצרפתי כהזדמנות; השניים כרתו חוזה, ובמשא ומתן ספקטור שתק ולא גילה כמה דירות ניתן לבנות, והקבלן חשב שניתן 16 דירות ולא שאל. **במבחן סובייקטיבי** ספקטור נהג בתום לב ("לא נשאל, וקבלן מקצועי יכול היה לבדוק מידע פומבי"). **במבחן האובייקטיבי** נשאלת השאלה מה החברה מצפה ממוכר. **המחלוקת:** השופט אשר – לפי ערכי החברה חובה לגלות, והיכולת של הצד השני לבדוק בעצמו אינה משחררת מהחובה; השופט לנדוי – אין לגלות, ויש גבול לדאגה הנדרשת כלפי אנשי עסקים. עם השנים **המגמה המרחיבה** (חובת גילוי) ניצחה.

⚖ פסק דין — פנידר נ׳ קסטרו (ד״נ 7/81) – מקרה פשוט, וחובה אישית

קסטרו, חבר ילדות של מנהל חברת נדל״ן "פנידר" (פניני), רכש ממנה יחידת דיור בפרויקט. אחרי החתימה התגלה שהמגרש כלל לא היה בבעלות החברה ובעליו לא התכוון למכור. החברה נקלעה לפירוק (קסטרו צפוי לקבל כ-10%), והוא תבע **אישית** את המנהל בטענת חוסר תום לב. פניני טען שאינו "צד" לחוזה, ולכן סעיף 12(ב) אינו חל עליו. **החידוש:** החובה לנהוג בתום לב במשא ומתן היא חובה אישית החלה על כל אדם שמשתתף בפועל במשא ומתן, בלי קשר לשאלה אם יהיה צד פורמלי לחוזה. לכן מנהל, עורך דין או נציג מכירות שנהגו שלא בתום לב חשופים לתביעה אישית.

ב. ניהול משא ומתן ללא כוונת התקשרות ("סרק")

⚖ פסק דין — קוט נ׳ ארגון הדיירים (ע״א 800/75)

ארגון הדיירים ניהל משא ומתן עם קוט למכירת חנות, הצדדים סיכמו פרטים ונשלחה טיוטת חוזה. קוט גילה שבזמן המשא ומתן החנות כבר נמכרה לאחר בחוזה מחייב. הארגון טען שזו הייתה טעות, בלבול וחוסר תשומת לב, בלי כוונה לפגוע. **בית המשפט:** תום הלב **אינו מחייב כוונת זדון**; המבחן אובייקטיבי. מי שמנהל משא ומתן צפוי לוודא שהוא מסוגל לקיים את החוזה. ניהול משא ומתן "סרק" – גם מרשלנות – הוא חוסר תום לב.

המשמעות: המונח המשפטי "תום לב" רחב מהמשמעות היום-יומית וכולל גם **רשלנות**. אין זהות מוחלטת (לא כל רשלנות היא חוסר תום לב), אך יש חפיפה משמעותית.

ג. "אשם בהתקשרות": חסימת הצד השני

⚖ פסק דין — שיכון עובדים נ׳ זפניק (ע״א 829/80)

"שיכון עובדים" יצאה במבצע סוף שנה: הנחה של 20% למי שירשם ויפקיד פיקדון עד שעה 12:00. בני הזוג זפניק הגיעו בזמן, אך מרוב עומס ובלגן של החברה נסגרו הדלתות והם נמנעו מלהירשם. החברה טענה שמי שלא חתם ולא שילם בזמן – המבצע אינו חל. בסוף הגיעו לפשרה (הנחה של 10%), והזוג תבע את ההפרש. בית המשפט דחה את התביעה (בשל הפשרה), אך השופטת בן-פורת קבעה באמרת אגב שאלמלא הפשרה הייתה פוסקת לטובתם, כי התנהגות החברה היא "אשם בהתקשרות": צד אחד חוסם באופן אקטיבי את השני ומונע ממנו לכרות את החוזה, ואחר כך טוען "לא נכרת חוזה". אדם אינו יכול להיות גם האשם במניעת הפעולה וגם מי שנהנה מכך שלא נעשתה. **לתרופות ראו פרק 6.**

ד. פרישה ממשא ומתן

הרחבה של "אשם בהתקשרות": קטגוריה רחבה ופחות קיצונית; "אשם בהתקשרות" הוא המקרה הקיצוני ביותר של פרישה.

שלב המשא ומתן	הכלל
תחילה ואמצעית	חופש מוחלט: אפשר "לקום וללכת" מכל סיבה, גם סתם כי לא מעוניינים
שלב מתקדם	נוצרת "ציפייה לגיטימית" לפי ערכי החברה שהמהלך יושלם לחוזה; פרישה דורשת הצדקה עניינית וטובה. אסורה "סתם" או רק כי העסקה נראית פתאום פחות משתלמת כלכלית

הצדקות אפשריות: שינוי קיצוני בנסיבות (מלחמה, אסון טבע), גילוי תרמית של הצד השני, נסיבות חריגות אחרות. **קושי:** אין "סרגל" – אין הגדרה של "שלוש שעות לפני חתימה". ההכרעה בשאלה אם הגענו ל"שלב מתקדם" נשענת שוב על ערכי החברה, ומתבררת מהפסיקה.

⚖ פסק דין — מזר נ׳ גאון

בני הזוג מזר חתמו עם חברה קבלנית (גאון) במשרד המכירות על "הצעת רכישה" מפורטת: זהות הצדדים והדירה, מחיר ומועדי תשלום, הקונים נושאים בהוצאות, תנאי של היתר בנייה (אם לא יתקבל בתוך שלושה חודשים הקונים רשאים לבטל), דמי רצינות של 5,000 ₪. ההיתר התעכב ואז התקבל, והקבלן שלח חוזה מפורט שכלל סעיף שהקונים נושאים בהוצאות עד 15,000 דולר. הקונים מחקו אותו. נציג הקבלן הציב אולטימטום: "מחירי הדירות עלו ויש קונה שמציע 15,000 דולר יותר, אם עד מחר ב-16:00 לא תחתמו – הדירה תימכר לאחר". הקונים תבעו וביקשו צו מניעה זמני בטענה שכבר נכרת חוזה. **בית המשפט:** אין סיכוי טוב להוכיח כריתה – חסרים פרטים מהותיים (שטח הדירה, מפרט טכני לפי חוק המכר, ומועד תשלום שהקונים לא עמדו בו). בהיבט הצרכני הוסיף: אם יקבע בקלות שמסמך ראשוני הוא חוזה, קבלנים עלולים "לכלוא" צרכנים (מי שמתחרט לרוב הוא הצרכן), ולכן מחמירים בגמירת הדעת והמסוימות במערכות יחסים צרכניות. אבל בתביעה לפיצויים בגין חוסר תום לב: כל השופטים הסכימו שהקבלן נהג בחוסר תום לב: פרישה מאוחרת משיקולי כדאיות ברגע האחרון, באולטימטום ובסעיף חדש.

5.4 מכרז פרטי

✦ הגדרה — מכרז

החוק אינו מגדיר "מכרז". ההגדרה בפסיקה: תחרות ממוסדת. מי שיוזם (המזמין) אינו המציע אלא הניצע; הפנייה שלו לציבור היא **"הזמנה להציע הצעות"** ולא הצעה. המשתתפים מגישים הצעות והחוזה משתכלל כשהמזמין מקבל את ההצעה הזוכה. לא כל פנייה לקבלת הצעות היא מכרז: צריכה להיות מסגרת כללים מסודרת (מועד הגשה סופי, תנאי סף, קריטריונים לבחירה).

במכרז **פרטי** לא חל חוק חובת המכרזים (מכרזים ציבוריים) אלא חוק החוזים בלבד. לכן כללי ההתנהגות של המזמין נגזרים מחובת תום הלב (סעיף 12).

⚖ פסק דין — בית יולס נ׳ רביב (ד״נ 22/82)

חברה שביקשה לבנות בית אבות פרסמה הזמנה להציע הצעות (מכרז פרטי) וקבעה כתנאי סף ערבות בנקאית. שתי חברות צירפו ערבות; חברה שלישית, "רסקו", לא צירפה (בטענה שהיא חברה גדולה בבורסה). בית יולס בחרה דווקא ברסקו. שתי האחרות תבעו בטענת הפליה. בדעת רוב נקבע באותה תקופה שאין חובת שוויון במכרז פרטי, בהסתמך על **חופש החוזים** (אדם פרטי מחליט עם מי ובאילו תנאים להתקשר) ועל כך שבמכרז פרטי המשתתפים אינם מצפים לשוויון מוחלט.

⚖ פסק דין — קל בניין נ׳ ע.ר.מ. רעננה (ע"א 4850/96)

ע.ר.מ. פרסמה מכרז פרטי לעבודות תשתית, וציינה שהיא עשויה לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הטובה, ושהקיבול ישתכלל רק לאחר החלטה רשמית של מועצת המנהלים שתירשם בפרוטוקול. קל בניין הגישה הצעה ונוהל איתה משא ומתן אינטנסיבי, והושגו הסכמות מלאות. רגע לפני אישור מועצת המנהלים הגיעו הצעות חדשות מחברות שלא השתתפו במכרז, וע.ר.מ. התקשרה עם אחת מהן. קל בניין טענה: (1) נכרת חוזה; (2) לחלופין, חוסר תום לב במשא ומתן (פרישה בשלב מתקדם בלי הצדקה). **הכרעה:** לא נכרת חוזה (הפרוטוקול של מועצת המנהלים היה תנאי לכריתה), אך ע.ר.מ. נהגה בחוסר תום לב קיצוני. התרופה ומהפכת הפיצויים: ראו פרק 6.

5.5 שלד לפתרון שאלה על תום לב במשא ומתן

1. **שלב המשא ומתן:** מתחילת/אמצע (חופש) או מתקדם (ציפייה לגיטימית)?
2. **סוג ההתנהגות:** אי-גילוי (האם ערכי החברה מחייבים גילוי? מקרה קל או קשה?), משא ומתן סרק, חסימת הצד השני (אשם בהתקשרות), פרישה ללא הצדקה עניינית, הטעיה.
3. **המבחן:** אובייקטיבי – ערכי החברה, גם בלי כוונת זדון; רשלנות עשויה להספיק.
4. **על מי חלה החובה:** כל מי שמשתתף בפועל במשא ומתן (פנידר) – ניתן לתבוע גם אישית.
5. **סיבה עניינית לפרישה?** שינוי קיצוני בנסיבות, תרמית, נסיבות חריגות; לא "כדאיות כלכלית פתאומית".
6. **תרופה:** פרק 6.

5.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "תום לב דורש כוונת זדון" – לא. המבחן אובייקטיבי; רשלנות יכולה להספיק (קוט).
- "מותר לפרוש בכל שלב כי טרם נחתם חוזה" – לא. בשלב מתקדם נדרשת הצדקה עניינית.
- "החובה חלה רק על מי שיהיה צד לחוזה" – לא. החובה אישית (פנידר).
- "הצד השני יכול היה לבדוק, ולכן אין חובת גילוי" – לא בהכרח (אשר מול לנדוי; המגמה המרחיבה ניצחה).
- "אשם בהתקשרות = פרישה רגילה" – לא. הוא המקרה הקיצוני: חסימה אקטיבית.
- "במכרז פרטי חלה חובת שוויון כמו במכרז ציבורי" – לא (בית יולס, באותה תקופה). במכרז פרטי חל חוק החוזים, ותום הלב.
- "הזמנה להציע הצעות היא הצעה" – לא. היא הזמנה; ההצעה היא של המשתתף, והקיבול של המזמין.

5.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- סעיף 12: חובת תום לב ו"דרך מקובלת" במשא ומתן; מהפכה מ"תחרות" ל"שותפות". המבחן **אובייקטיבי** (ערכי החברה).
- צורות הפרה: **אי-גילוי** (ספקטור – קשה; פנידר – קל), **משא ומתן סרק** (קוט – גם רשלנות), **אשם בהתקשרות** (זפניק), **פרישה** בשלב מתקדם בלי הצדקה ענייינית (מזר, קל בניין).
- החובה **אישית** (פנידר) וחלה על כל משתתף במשא ומתן.
- מכרז = תחרות ממוסדת; ההזמנה היא "הזמנה להציע הצעות"; במכרז פרטי חל חוק החוזים ותום הלב (בית יולס).

פרק 6

תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

6.1 מבוא: מפת הדיון

אחרי שזיהינו חוסר תום לב במשא ומתן (פרק 5), נשאלת השאלה: **מה התרופה?** הדיון מתחלק לשני מצבים:

	מצב א׳	מצב ב׳
העובדות	המשא ומתן נכשל, **לא נכרת חוזה**, ואחד הצדדים נהג שלא בתום לב	המשא ומתן הצליח, **נכרת חוזה**, והנפגע מבקש פיצוי על חוסר תום לב בשלב המשא ומתן (בדרך כלל אי-גילוי או הטעיה)
פרשות	זפניק, קל בניין, בית יולס, פרינץ נ׳ אמירים	נטע מור
ברירת מחדל	פיצויי הסתמכות; במקרים חריגים – פיצויי קיום; לעיתים נדירות – אכיפה	ביטול (פרק ב׳) + הסתמכות, או פיצוי בלי ביטול (הפרש תמורה / ניכוי מהמחיר)

6.2 שלוש התרופות האפשריות

תרופה	מקורה	מתי
פיצויים	סעיף 12(ב) – התרופה היחידה שהמחוקק ברוב המכריע של המקרים מציין במפורש	
אכיפה	לא כתובה בחוק; הפסיקה (בן-פורת בזפניק): סעיף 12(א) כעקרון-על חולש	במקרים חריגים וקיצוניים בלבד – "אשם בהתקשרות": יש לראות את הפעולות שלא בוצעו בשל חסימת הצד השני כאילו בוצעו
ביטול	לא מסעיף 12; רק מפרק ב׳ לחוק החוזים (טעות, הטעיה, כפייה, עושק)	כדי לבטל חוזה לא מספיק חוסר תום לב כללי

! שים לב — ביטול הוא תרופה דרסטית

לא ניתן לבטל חוזה מכוח סעיף 12. ביטול דורש עמידה בתנאים המחמירים של עילות פרק ב׳ (נלמד בפרק 8). מי שמבקש לבטל בגלל מה שהיה במשא ומתן – פונה לפרק ב׳; מי שרוצה כסף ולא ביטול – סעיף 12.

✦ הגדרה — אשם בהתקשרות – התרופה

לפי בן-פורת: סעיף 12(א) הוא חובה כללית ללא מגבלה ("עקרון-על חולש") ולכן לבית המשפט סמכות טבועה למצוא פתרון מתאים בנסיבות – גם אכיפה. סעיף 12(ב) אינו מגביל את רשימת התרופות אלא אומר: אם נבחר מסלול פיצויים – הנה הכללים. זו **קריאה חדשנית ("דרש")**, לעומת הקריאה המסורתית ("פשט"): 12(א) חובה, 12(ב) הסנקציה (פיצויים).

6.3 פיצויי קיום מול פיצויי הסתמכות

	פיצויי קיום ("חיוביים")	פיצויי הסתמכות ("שליליים")
מטרה	להעמיד את הנפגע במקום שבו היה אילו החוזה קוים	להחזיר את הנפגע למקום שבו היה לפני המשא ומתן
בשפה פשוטה	פיצוי על **אובדן רווח** ("מבחן הארנק")	**החזר הוצאות** שהוציא בהסתמך על כך שייכרת חוזה (עורכי דין, נסיעות, בדיקות)
דוגמה	שווי שוק 110, מחיר 100 → ה"פלוס" של 10 הוא הרווח הצפוי	תשלום לעורך דין ולמתווך
בסעיף 12	חריג: רק ב"אשם בהתקשרות" ובמצבי קל בניין **הכלל** (כי לא נכרת חוזה, והנזק הטיפוסי הוא בזבוז ההוצאות)	

שני תנאים לכל פיצוי: קשר סיבתי (הנזק נגרם ישירות בשל חוסר תום הלב) והוכחת שיעור הנזק. עדיין אי אפשר לבטל ולדרוש קיום יחד: ביטול אומר "כאילו לא היה", וקיום אומר "כאילו כן היה" – סותרים.

6.4 מצב א׳: לא נכרת חוזה

⚖ פסק דין — קל בניין נ׳ ע.ר.מ. רעננה (ע"א 4850/96 + ע"א 6370/00) – הלכת פיצויי הקיום

(עובדות בפרק 5.) הרוב קבע שלא נכרת חוזה (הפרוטוקול של מועצת המנהלים כתנאי לקיבול), אך ע.ר.מ. נהגה בחוסר תום לב קיצוני. בפסק הדין המשלים נקבעה ההלכה: כשהמשא ומתן הושלם והפרטים ידועים, והסיבה היחידה לכך שלא נכרת חוזה היא חוסר תום לב של צד אחד, כך שאפשר לומר שאילו נהג בתום לב החוזה היה נכרת – הנזק הוא אובדן החוזה עצמו, והנפגע זכאי לפיצויי קיום, ולא רק להסתמכות. זה המקום הראשון שבו העליון מאפשר פיצויי קיום בגין חוסר תום לב במשא ומתן. אמרו שהדבר שמור למקרים חריגים, אך בפועל אחרי קל בניין "הסכר נפרץ".

⚖ פסק דין — בית יולס – מתי אי אפשר לפסוק קיום

אם המזמין בוחר בהצעה שלא עמדה בתנאי הסף – לא ניתן לפסוק פיצויי קיום, גם אם נניח שהייתה הפרת תום לב: **אי אפשר לדעת מי היה זוכה** אילו נהג כראוי (רביב? אחרת?). פיצויי קיום אפשריים רק כשניתן לומר בבירור שהחוזה לא נכרת בגלל חוסר תום הלב ושאילו נהג בתום לב החוזה היה נכרת.

★ טיפ למבחן — תנועת המטוטלת

נקבעת הלכה, המטוטלת הולכת לקצה אחד, ואז מתחילה תנועה חזרה עד שמגיע מקרה שמחזיר את הדברים לפרופורציה. אחרי קל בניין פיצויי הקיום נכנסו ל"אופנה". כעבור שנים הגיעה פרינץ נ׳ אמירים: ההלכה לא השתנתה אך יישומה נעשה שקול ומאוזן.

⚖ פסק דין — פרינץ נ׳ אמירים (ע"א 434/07)

בני הזוג פרינץ, שגרו בשכירות ביישוב אמירים (מושב של צמחונים וטבעונים), רצו להתקבל כחברים. תקנון היישוב דורש שחבר יהיה צמחוני/טבעוני והורה לילדים, והם לא היו (ועדיין אין להם ילדים). הוועד הפנה אותם למבחנים ואחר כך לקנות נכס; אמרו להם לקנות "משק", אך הם קנו בחשאי "נחלה" (שבמוקד מחלוקת פנימית ביישוב) והסתירו זאת, אף שאלו את הוועד "בתמימות" על תוכניותיו לנחלה. הוועד גילה, שלח מכתב דחייה בלי נימוקים, ואז "באופן לא פורמלי" הציע לדון אם יוותרו על הנחלה. פשרה לא הושגה. הם תבעו, לבסוף פיצויי קיום (אילו התקבלו כחברים היו מקבלים מגרש נוסף בהרחבה).

המחוזי: פרישה בשלב מתקדם בחוסר תום לב; הלכת קל בניין – פיצויי קיום. אך **אשם תורם** של 50% (הסתרת רכישת הנחלה) ועוד 50% מהיתרה בגין אי-הקטנת נזק (סירוב לפשרה) – נותרו 25% מהקיום.

העליון (השופט רובינשטיין): התנהגות הוועד אכן חוסר תום לב, ולפרינץ אשם תורם. אבל **אין פיצויי קיום, משתי סיבות, וכל אחת מספיקה:** (1) *הסיבה הראשונה:* אתה עדיין לא צמחוני, לא טבעוני ואין לך ילדים – המשא ומתן לא הבשיל, אי אפשר לומר בוודאות של 100% שהיה חוזה; גם בפרישה בחוסר תום לב נקודת המוצא היא **הסתמכות**, וקיום רק כשחוסר תום הלב קיצוני וניתן לומר בוודאות שאלמלא הוא היה נכרת חוזה; (2) *הסיבה השנייה:* האשם התורם – קיום הוא תרופה קיצונית "השמורה ל'צדיקים'"; מי שיש פגם מוסרי בהתנהגותו לא יקבל קיום. **התוצאה:** פיצויי הסתמכות בלבד; האשם התורם הועמד על **20%** (במקום 50%) והופחתה ההפחתה בגין אי-הקטנת נזק, כי הצעת הפשרה לא הייתה הוגנת; **נפסקו 80%** מפיצויי ההסתמכות.

✔ שורה תחתונה — מצב א׳ – שורה תחתונה

ברוב המכריע של המקרים של משא ומתן שנכשל בחוסר תום לב: **פיצויי הסתמכות**. במקרים חריגים (קל בניין): **פיצויי קיום**, רק כשחוסר תום הלב קיצוני וברור שאלמלא הוא היה נכרת חוזה, ורק ל"צדיק". לעיתים נדירות מאוד – אכיפה ("אשם בהתקשרות").

6.4א אשם תורם והקטנת נזק

אשם תורם: הנפגע עצמו התנהג שלא בתום לב והתנהגותו תרמה לנזק. בית המשפט רשאי להפחית ולעיתים לשלול פיצוי (בדרך כלל באחוזים). **הקטנת נזק:** חובת הנפגע לפעול סביר להקטין את הנזק (למשל לקבל הצעת פשרה הוגנת). שניהם מפחיתים את הפיצוי.

6.5 מצב ב׳: נכרת חוזה – נטע מור (ע"א 2274/21)

בפועל, כשנכרת חוזה ויש טענה לחוסר תום לב במשא ומתן, מדובר בדרך כלל ב**אי-גילוי** או **הטעיה** (ברוב המקרים אי-גילוי).

> ⚖ **פסק דין — נטע מור נ׳ אלעד ישראל מגורים**
>
> רוכשת רכשה דירה בקומה השלישית בפרויקט יוקרתי של שני מגדלים ובניין לרווחת הדיירים (בריכה, חדר כושר) באמצע. רק אחרי הכריתה התברר שבחלק משמעותי מהדירה, במרחק של מטרים, ניצב קיר של בניין הדיירים – הדירה חסומה. **זו אינה הפרת חוזה:** אף אחד לא התחייב שהדירה לא תהיה חסומה (אילו הייתה התחייבות כזו – פיצויי קיום). הבעיה: **אי-גילוי / מצג שווא**. בין קבלן לצרכן יש פערי כוח ומידע, ובעסקת "דירה על הנייר" מצופה מהקבלן חובת גילוי יזומה ומשמעותית יותר, גם אם רוכש מומחה היה מזהה בתוכניות.

הבעיה: איך מפצים כשהחוזה לא בוטל?

- **אם הנפגעת מבטלת מכוח פרק ב׳:** השבה (כל צד מחזיר את מה שקיבל) + **פיצויי הסתמכות** מסעיף 12 על ההוצאות הנוספות (שכר טרחת עורך דין וכו׳). אי אפשר גם לבטל וגם לדרוש פיצויי קיום.
- **אם היא לא מבטלת** (וזה היה המצב בנטע מור): אי אפשר לתת קיום (לא התחייבו לדירה לא חסומה); וקשה לתת הסתמכות רגילה (איך מחזירים את המצב לקדמותו בלי לבטל?). מהו הנזק?

המסלולים לפיצוי בלי ביטול

מסלול	הנחה	איך מחשבים
1. אלמלא הטעות לא הייתי נכנס לחוזה	מחזירים כלכלית למצב שבו לא נכרת חוזה: "פיצוי לפי הפרש התמורה החוזית"	כמה יצא מהכיס פחות שווי מה שהתקבל בפועל
2. אלמלא הטעות הייתי נכנס – אבל במחיר נמוך (חידוש השופט שטיין)	"התאמת מחיר" רטרואקטיבית – ניכוי מהמחיר (בהשראת סעיף 28 לחוק המכר)	שיטה יחסית: AV/HV × מחיר החוזה

> ✎ **דוגמה — דוגמה מספרית (מחיר חוזה 100)**
>
> מחיר החוזה: **100**. שווי שוק של נכס תקין (HV): **120**. הוצאות נלוות (מתווך, עו״ד, אגרות): **10**. שווי בפועל של הנכס הפגום (AV): **90**.
>
> - **ביטול:** השבה (הקונה מחזיר את הנכס ומקבל 100) + פיצויי הסתמכות של **10** על ההוצאות = חוזר בדיוק למצב שלפני העסקה.
> - **פיצויי קיום** (להשוואה בלבד; רלוונטי להפרת חוזה ולא לאי-גילוי): **30** – הפער בין 120 ל-90 (או: במקום הפסד של 20 – רווח צפוי של 10).
> - **הפרש התמורה החוזית** (בלי ביטול; "אלמלא הטעות לא הייתי נכנס"): הוציא 110 וקיבל 90 → **20** (10 הוצאות + 10 פער). הקונה נשאר עם הנכס הפגום וחוזר לנקודת האפס.
> - **ניכוי מהמחיר (שטיין):** יחס AV/HV = 90/120 = 0.75; מחיר מותאם = 100 × 75% = **75**; פיצוי = 100 − 75 = **25**. "דרך אמצע" בין הסתמכות (20) לקיום (30).

! שים לב — למה המסלול המסורתי נכשל בנטע מור

בשל עליית מחירי הנדל"ן בשוק, שווי הדירה הפגומה ביום המסירה (למשל 115) היה גבוה מהסכום שהוציאה (110) – היא אפילו ברווח של 5. לפי הפרש התמורה: אין "חור כספי" ולכן אין פיצוי. כדי לעשות צדק עם הנפגעת (שבחרה להישאר בחוזה, ולכן ברור שהיא עדיין מעוניינת בנכס) ייבא השופט שטיין את הכלי "ניכוי מהמחיר" לשלב המשא ומתן, ובכך "דילג" מעל עליית מחירי השוק. זהו מהלך חדשני ושנוי במחלוקת דוגמטית.

ראשי נזק נוספים (תיאורטיים)

- **עלות עודפת בניהול המשא ומתן:** הוצאות מיוחדות שהוציא הנפגע בגלל החשד או ניסיון לברר את המידע שהוסתר. בפועל פחות שימושי: עצם אי-הידיעה בדרך כלל אינו גורם להוצאות נוספות.
- **אובדן הזדמנויות (עסקה חלופית):** "אלמלא הטעות הייתי קונה דירה אחרת ומרוויח". עלול להגיע לסכומים עצומים, גבוהים לעיתים מקיום; לכן המדיניות לא לפסוק אותו, מחשש ל"מדרון חלקלק" ולתביעות ספקולטיביות. תנאים להוכחה: בחירה בין **שתי** עסקאות מוגדרות בלבד, הצגת פרטי שתיהן בבהירות, והוכחה משכנעת שאלמלא הראשונה היה מתקשר בשנייה. נטע מור, שהתלבטה בין חמש דירות, לא עמדה בנטל.

6.6 שלד לפתרון שאלה על תרופות לחוסר תום לב

1. **האם נכרת חוזה?** לא → מצב א׳. כן → מצב ב׳.
2. **מצב א׳:** התרופה הרגילה – **הסתמכות**. האם מדובר בחוסר תום לב קיצוני וביכולת לומר בוודאות שאלמלא הוא היה נכרת חוזה (קל בניין)? אם כן – **קיום**. מי היה זוכה? (בית יולס – אם לא ברור, אין קיום.) האם הנפגע "צדיק" (פרינץ)? האם אשם תורם / הקטנת נזק? ב"אשם בהתקשרות" קיצוני – אכיפה (בן-פורת).
3. **מצב ב׳:** האם הנפגע מבטל (פרק ב׳)? כן – השבה + הסתמכות (לא קיום). לא – קשה לתת קיום (אין התחייבות) ו/או הסתמכות רגילה; חשבו הפרש תמורה ואת הניכוי מהמחיר (שטיין).
4. **תמיד:** קשר סיבתי והוכחת שיעור הנזק.
5. **לא ניתן לבטל** מכוח סעיף 12.

6.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "אפשר לבטל חוזה בגלל חוסר תום לב" – לא. ביטול רק מפרק ב׳.
- "אפשר גם לבטל וגם לקבל פיצויי קיום" – לא. סותרים. אחרי ביטול – הסתמכות בלבד.
- "בכל פרישה בחוסר תום לב מגיעים פיצויי קיום" – לא. נקודת המוצא הסתמכות; קיום רק בקל בניין.
- "בנטע מור הקבלן הפר חוזה" – לא. לא הייתה התחייבות לדירה לא חסומה; זו שאלה של אי-גילוי.
- "פיצוי על אובדן הזדמנויות נפסק בקלות" – לא. כמעט לא נפסק.
- "אשם תורם מבטל את הזכות לפיצוי" – לא בהכרח; מפחיתים באחוזים (ולעיתים שוללים).
- לבלבל בין **הסתמכות** כראש נזק לבין **הסתמכות** כעיקרון של כריתה (פרק 2).

6.8 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- התרופות: **פיצויים** (12(ב); הרגילה), **אכיפה** (חריג קיצוני – אשם בהתקשרות), **ביטול** (רק פרק ב׳).
- **הסתמכות** = החזר הוצאות (הכלל בסעיף 12); **קיום** = אובדן רווח (חריג – קל בניין).
- **קל בניין:** קיום כשהמשא ומתן הושלם והסיבה היחידה להיעדר חוזה היא חוסר תום לב. **בית יולס:** אין קיום כשלא ברור מי היה זוכה. **פרינץ:** אין קיום אם המשא ומתן לא הבשיל ואם הנפגע אינו "צדיק"; הסתמכות, 80%.
- **נטע מור:** חוזה נכרת + אי-גילוי: ביטול + הסתמכות; או בלי ביטול – הפרש תמורה (20) או ניכוי מהמחיר (שטיין, 25). אובדן הזדמנויות – כמעט לא.

פרק 7

צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

7.1 מבוא: למה "צורת החוזה" נלמדת אחרי גמירת דעת ומסוימות

עד כה למדנו שכדי שייכרת חוזה צריך **העדה על גמירת דעת ומסוימות**. הנושא האחרון בפרק א׳ הוא **צורת החוזה**: לפעמים נדרש, מעבר לגמירת דעת ומסוימות, שהחוזה ייעשה בצורה מסוימת. הנושא נשמר לסוף כי ברוב המכריע של המקרים אין דרישת צורה.

§ סעיף — סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי)

חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת (בהתנהגות), זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

מבחינת חוק החוזים (חלק כללי – שחל על כל החוזים) אין דרישת צורה. יש **שני חריגים**:

חריג	מהות
1. הסכם בין הצדדים	ההסדר דיספוזיטיבי: אנשים רשאים להחליט שביניהם יהיה חוזה רק אם ייעשה מסמך בכתב, רק אם יחתמו וכד׳. חלק מחופש החוזים: אם הם התנו – כך יהיה
2. חוק	חוקים מיוחדים שדורשים צורה: סעיף 8 לחוק המקרקעין; חוק המתנה; חוק הלוואות חוץ-בנקאיות; חוק יחסי ממון בין בני זוג. **בקורס זה:** רק חוק המקרקעין (העקרונות רלוונטיים, בשינויים המחויבים, גם לאחרים)

7.2 סעיף 8 לחוק המקרקעין: דרישת כתב מהותית

§ סעיף — סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969 (ללמוד בעל פה)

התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

חשוב ללמוד בעל פה כי הנוסח מזהה את סוג הדרישה: למשל סעיף 5 לחוק המתנה – "התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב" – כמעט זהה, ומיד אפשר להסיק שגם שם מדובר בדרישת כתב מהותית.

דרישת כתב ראייתית לעומת מהותית

	כתב ראייתי (דיני ראיות)	כתב מהותי (דיני חוזים)
מקור	חוק הפרוצדורה האזרחית העותמני (עדיין בתוקף) – עסקאות מסוימות (שותפות, הלוואות, מחסנות)	סעיף 8 לחוק המקרקעין (1969) – "מהפכה"

מטרת הכתב	להוכיח שהיה חוזה	ליצור את החוזה
החוזה עצמו	יכול להיות בעל פה	חייב להיות בכתב
מה נדרש	ראשית ראיה בכתב כנקודת פתיחה; אחר כך כל הראיות (עדים, נסיבות)	הפרטים החשובים של העסקה בכתב
נוסח	"צריך להוכיח במסמך בכתב"	"טעונה מסמך בכתב" – נוסח מהותי

✎ דוגמה — דוגמת 1/1: פתק "קיבלתי 50,000 דולר"

ביום ראשון שני צדדים מסכמים **בעל פה** מכר מגרש (יש גמירת דעת ומסוימות), והקונה מוסר מזוודה עם 50,000 דולר "על החשבון". ביום שני הקונה מוטרד, והמוכר כותב לו פתק: "קיבלתי 50,000 דולר" (בלי שמות, תאריך או עסקה). ביום שלישי המוכר מתחרט. **ב-1968 (כתב ראייתי):** החוזה נכרת ביום ראשון בעל פה; ביום שני יש "ראשית ראיה" בכתב – **המוכר לא יכול להתחרט**. **ב-1970 (כתב מהותי):** ביום ראשון לא נכרת חוזה כלל (הכתב צריך ליצור אותו); הפתק אינו מסמך חוזי שמגלם את ההתחייבות לעסקת מקרקעין – **המוכר רשאי להתחרט**.

⚖ פסק דין — גרוסמן נ׳ בידרמן (ע״א 726/71)

הסיפור של דוגמת 1/1, בשינויים קטנים, אחרי חקיקת חוק המקרקעין. העליון: סעיף 8 הוא דרישת כתב מהותית של דיני חוזים, לא דיני ראיות. **שתי סיבות:** (1) *הנוסח* ("טעונה מסמך בכתב" לעומת "צריך להוכיח במסמך בכתב"); (2) *תכלית*: מקרקעין זו עסקה משמעותית ובעלת ערך כספי רב, ואין רצון שאנשים יהיו פזיזים ויבטיחו בעל פה. מטרת הדרישה לחזק את הרצון המגובש של הצדדים לעסקה – עוד מחסום שמכריח לחשוב.

מה נדרש בכתב?

- **הפרטים החשובים של העסקה** (אותם הפרטים המהותיים ממסוימות – אין מספר קבוע של פרטים; תמגר נ׳ גושן, ע״א 3380/97; אג׳מי). ייתכן שהצדדים סיכמו בעל פה את כל הפרטים והתנהגו במאה אחוז כמי שגמרו דעתם, אבל בכתב רשמו רק חלק (למשל לא את המחיר): יש גמירת דעת ומסוימות, אך אין דרישת כתב – ולכן אין חוזה.
- פרטים לא חשובים אפשר לסכם בעל פה או לא לסכם בכלל.
- **חתימה אינה חלק מדרישת הכתב.** סעיף 8 דורש מסמך בכתב, לא חתימה. החתימה היא אינדיקציה חשובה (ברוב המקרים הטובה ביותר) ל**גמירת הדעת**, ושייכת לדיון בה.

⚖ פסק דין — בודקובסקי נ׳ גת (ע״א 692/86)

נציגי שתי חברות ניהלו משא ומתן למכירת מגרש שעתיים-שלוש, והמסמך שנוצר היה "דף מקושקש", מלא מחיקות וכוכביות (מחיר 100 → 80 → 90...). בסוף סיכמו את כל הפרטים החשובים, שמחו, והחליטו שמישהו יקליד נקי ויחתמו בעוד יומיים. במהלך 48 השעות אחד התחרט. נטען שאין חתימה ולכן אין כתב. העליון: סעיף 8 דורש כתב ולא חתימה; החתימה היא עניין של גמירת דעת, ובנסיבות אלה (הסיכום, והסיבה הטכנית שלא חתמו) הייתה גמירת דעת גם בלי חתימה. מקרה לא שכיח, אך ממחיש שהמבחן הוא גמירת דעת ולא חתימה.

7.3 דרישת הכתב מול תום הלב

סגירת מעגל לזפניק (פרק 5): בפסיקה התפתחה הלכה שלפיה מי שבגלל חוסר תום הלב שלו לא התקיימה דרישת הכתב – מנוע מלטעון שדרישת הכתב לא התקיימה. בקיצור: "תום הלב גובר על דרישת הכתב". זו ההלכה שמהווה אכיפה של חוזה ("אשם בהתקשרות") גם בלי כתב.

⚖ פסק דין — קלמר נ׳ גיא (ע״א 986/93) – ההלכה

עובדות: עסקת קומבינציה: בעל מגרש גדול בהרצליה (כ-1,500 מ״ר, שאפשר לבנות עליו שני בתים) הגיע להסכמה עם בני זוג אדריכלים ואנשי נדל״ן: ימכור להם חצי מגרש, והתמורה בנייה – שני בתים, אחד להם ואחד לו. בעקבות ייעוץ מס (חשש מדיווח על מכירה לפני שהבתים יושלמו כדי ליהנות מהטבת מס) ביקש מהם לא לכתוב ולא לדווח. הם בנו בפועל שני בתים, נפתחו חשבונות, הוגשו בקשות להיתרי בנייה בחתימת שני הצדדים, הועבר אליו זיכרון דברים והונחה לא לחתום. הבתים הושלמו והצדדים נכנסו לגור. אז טען בעל המגרש: אין חוזה, אין כתב (סעיף 8), אשלם על הבנייה בלבד.

דעת הרוב (ברק וגולדברג): הסיבה שדרישת הכתב לא התקיימה היא חוסר תום הלב של בעל המגרש – "זעקת ההגינות": צד אחד יוזם שלא יהיה כתב, השני מבצע את חלקו ומעשיר אותו, ואז נזכר שאין כתב. **תום הלב גובר על דרישת הכתב**; נכרת חוזה למרות שאין מסמך כנדרש בסעיף 8.

דעת המיעוט (זמיר): לקבוע שתום הלב גובר זו כמעט מחיקה של סעיף 8; מי שנהג שלא בתום לב ישלם פיצויים. אך הגיע לאותה תוצאה כי לשיטתו **"הכתב הוא הביצוע"** – העסקה "נכתבה" בבניית שני הבתים. אלגנטי לכבוד החוק, אך ביקורת: לא ברור שבניית בית היא "מסמך בכתב".

הצמצומים בהלכה

פרשה	נסיבות	הצמצום
אלריג נ׳ ברנדר **לוין נ׳ שולר**	אנשי עסקים בעסקת נדל״ן מסחרית: א׳ מחזיק מגרש; ב׳ מממן בעל פה רכישת חלקות עירייה (רשומות על שם א׳) תמורת 25% מהמגרש הגדול; א׳ התקשר עם ג׳ למכור הכול וטען "אין כתב". המחוזי: כמו קלמר. משפחה שמוכרת כמה דירות ורוצה "להעלים מס" בדחיית הדיווח; הקונים שילמו סכום גדול, נכנסו לגור וחתמו על זיכרון דברים "רזה" (שמות, זיהוי נכס, התחייבות למכור, בלי מחיר ומועדי תשלום). אחרי שנים המוכרים דרשו השלמה לפי שווי שוק. הקונים הוסיפו מחיר בכתב יד – חד-צדדית, ולא הועיל. שטרסברג-כהן (מיעוט): יש חוזה, והמחיר ניתן להשלמה (סעיף 46). הרוב: המחיר מהותי; סוכם בעל פה ולא נכתב – אין כתב, אין חוזה.	העליון לא חזר על ההלכה: (1) **אנשי עסקים בעסקה מסחרית** – "אל תעשו עסקה כזו בעל פה"; (2) כשהאינטרס כלכלי אפשר לתת **פיצוי קיום** ואין צורך במהלך הדרסטי של "תום הלב גובר על הכתב". **ידיים נקיות:** מי ששותף להעלמת מס ובא כדי "להינצל" באמצעות עקיפת דרישת הכתב – לא בהכרח יקבל את הסעד הדרסטי; ההלכה שמורה למקרים קיצוניים ולנפגעים "צדיקים". **איתות ביקורתי:** ההלכה שנויה במחלוקת וייתכן שצריך לחשוב עליה מחדש. לא די בהתנהגות לא ראויה של הצד השני: נבחנת גם התנהגות הנפגע.

שם טוב נ' פרץ עסקה במשפחה: קרוב משלם סכום מלא על בית בפרויקט משפחתי, הכול בעל פה מתוך אמון; עוברות שנים, מסירה והחזקה; אחרי סכסוך (גירושין) המוכרת טוענת "אין כתב".

ההלכה יושמה: "זעקת ההגינות", ולכן תום הלב גובר. **עמית:** ההלכה תחול בעיקר ב"מעשה עשוי" – עסקה שבוצעה באופן משמעותי (תשלום, מסירה, חזקה, ביצוע מהותי) ורק הכתב חסר; לא כשיש משא ומתן בלי ביצוע משמעותי. **חיות:** אפשר להחיל גם בלי "מעשה עשוי" בחוסר תום לב קיצוני שמסכל כתב. כיום יש מחלוקת, אך בפועל כמעט תמיד יושמה במקרים של "מעשה עשוי".

✔ שורה תחתונה — השורה התחתונה על ההלכה (קלמר ואחריה)

ההלכה קיימת, אך **מצומצמת מאוד** והיישום תלוי בפרמטרים: (1) **מי הצדדים** – עסקה מסחרית בין אנשי עסקים מול יחסים אישיים/משפחתיים; (2) **האם אפשר לתת פיצוי קיום** במקום "לעקוף" את דרישת הכתב; (3) **האם הנפגע בא בידיים נקיות**; (4) **האם יש "מעשה עשוי"** או שמדובר בשלב מוקדם בלי ביצוע משמעותי.

7.4 שלד לפתרון שאלה על צורת החוזה

1. **האם נדרשת צורה?** סעיף 23: בכלל לא. חריגים: חוק (מקרקעין, מתנה...) או הסכם בין הצדדים.
2. **במקרקעין:** האם יש מסמך בכתב שמכיל את **הפרטים החשובים** של העסקה? (לא חתימה.) כתב מהותי – משנה את התשובה לשאלה אם נכרת חוזה.
3. **אם אין כתב:** האם יש לטעון ש"תום הלב גובר על דרישת הכתב" (קלמר)? בדקו את ארבעת הפרמטרים: צדדים (עסקי/אישי), אפשרות לקיום, ידיים נקיות, מעשה עשוי.
4. **חלופה:** פיצויי קיום / הסתמכות / עשיית עושר ולא במשפט במקום חוזה.
5. **חתימה:** רלוונטית לגמירת דעת, לא לכתב.

7.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "חוזה חייב להיות בכתב" – לא. סעיף 23: ככלל אין דרישת צורה; במקרקעין – כן (סעיף 8).
- "סעיף 8 הוא דרישת כתב ראייתית" – לא. הוא מהותי (גרוסמן): הכתב יוצר את החוזה.
- "סעיף 8 דורש חתימה" – לא. הוא דורש כתב; חתימה נוגעת לגמירת דעת (בודקובסקי).
- "די בכל פתק שמוכיח תשלום" – לא. צריך מסמך שמגלם את הפרטים החשובים של העסקה.
- "תום הלב תמיד גובר על דרישת הכתב" – לא. מצומצם מאוד: אנשי עסקים? אפשר קיום? ידיים נקיות? מעשה עשוי?
- "אפשר להתנות על דרישת הכתב שבחוק" – לא בהכרח. סעיף 23 דיספוזיטיבי לגבי הסכמת הצדדים, אך חוקים מיוחדים דורשים צורה.

7.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- ככלל אין דרישת צורה (סעיף 23); חריגים: חוק והסכם בין הצדדים.
- סעיף 8 לחוק המקרקעין: דרישת **כתב מהותי** (גרוסמן): הכתב יוצר את החוזה; צריך לכתוב את הפרטים החשובים; **אין צורך בחתימה** (בודקובסקי).
- **קלמר נ׳ גיא:** תום הלב גובר על דרישת הכתב – מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיים הכתב מנוע מלטעון זאת. זמיר (מיעוט): "הכתב הוא הביצוע".
- ההלכה **מצומצמת**: אלריג (עסק + קיום), לוין נ׳ שולר (ידיים נקיות), שם טוב (מעשה עשוי; חיות מול עמית).

פרק 8

פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

8.1 מבוא: הקומה השנייה בארמון

פרק א׳ (כריתה) **אובייקטיבי**: די שהצופה מבחוץ הסיק שהצדדים רצו חוזה. פרק ב׳ הוא **סובייקטיבי**: הוא נפתח רק **אחרי שנכרת חוזה**, ועוסק במי שהתנהג כאילו רצה חוזה אך בעצם רצונו היה פגום. הרציונל: לכריתה מספיקה העדה על גמירת דעת, אך מי שלא באמת רצה – יוכל לבטל אם יעמוד בתנאי הפרק.

	פרק א׳ (כריתה, סעיף 12)	פרק ב׳ (פגמים)
מבחן	אובייקטיבי	סובייקטיבי (הרצון הפנימי הפגום)
מתי נבחן	לפני / בשלב כריתת החוזה	אחרי שנכרת חוזה
הסעד	פיצויים (הסתמכות/קיום) ובמקרים מיוחדים אכיפה	**ביטול החוזה** והשבה
תנאים	תום לב אובייקטיבי	רשימת תנאים מצטברים לכל עילה

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

בעילות פרק ב׳ התנאים מצטברים ומחמירים. כשאחד לא מתקיים – חוזרים לפרק א׳ ולתום הלב (סעיף 12), שמאפשר פיצויים. כך עשו בפרץ בוני הנגב (מחיר שוק – לא עושק) ובהדר (כפייה על ידי צד ג׳ – לא סעיף 17).

8.2 ארבע העילות

עילה	סעיף	מהות	התנאים העיקריים
טעות	14	המתקשר טעה בנוגע לעובדה	(1) טעות; (2) **יסודית** – אילו ידע לא היה מתקשר או היה מתקשר בתנאים שונים מהותית; (3) הצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות; (4) סיבתיות. **טעות בכדאיות העסקה אינה עילה**
הטעיה	15	הצד השני (או מי מטעמו) הטעה, כולל באי-גילוי כשחייב לגלות	(1) הטעיה (מצג או אי-גילוי); (2) סיבתיות – בלעדיה לא היה מתקשר; (3) מצד הצד השני או מי מטעמו
כפייה	17	איום שאינו כדין שנועד לגרום להתקשרות	(1) איום בלתי חוקי; (2) **מצד הצד השני או מי מטעמו**; (3) סיבתיות. כפייה על ידי צד ג׳ אינה עילה (הדר)
עושק	18	ניצול מצוקה, חולשה שכלית/גופנית או חוסר ניסיון	(1) ניצול; (2) התנאים גרועים **במידה בלתי סבירה** מהמקובל; (3) הצד השני ידע/היה עליו לדעת

! שים לב — כמה הערות

- **טעות** – טעות בכדאיות ("טעיתי בחישוב כמה ארוויח") לא תספיק; צריך טעות בעובדה יסודית.
- **הטעיה** לא דורשת כוונה; גם מצג שווא רשלני או אי-גילוי של עובדה שחובה לגלות. התהדרות בעלמא אינה הטעיה.
- **כפייה** – האיום חייב להיות "שלא כדין" ולבוא מהצד השני; בהדר האיום בא מהבעל (צד ג׳), ולכן סעיף 17 לא עמד.
- **עושק** – גרוע "במידה בלתי סבירה": לא די בעסקה פחות טובה. בפרץ בוני הנגב המחיר היה מחיר שוק.

8.3 איך מבטלים: סעיפים 20 ו-21

§ סעיף — סעיף 20 – אופן הביטול

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפייה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה.

- **הזמן הסביר מתחיל בגילוי** (בכפייה – בתום הכפייה, לא בכריתה). שיקול של ודאות מסחרית.
- **טענת הגנה:** שולחים הודעת ביטול; אם הצד השני תובע אכיפה, בית המשפט בוחן אם הביטול כדין.
- **סעד הצהרתי:** אפשר לבקש הצהרה שהוא זכאי לבטל – פחות פרקטי (הליך מלא).
- **סיכון:** ביטול שלא כדין (תנאים לא מתקיימים) = הפרת חוזה מצד המבטל! לכן חשוב לוודא שעומדים בתנאים.

§ סעיף — סעיף 21 – השבה

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

ההתחשבנות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל״ט-1979.

✔ שורה תחתונה — פרק ב׳ + סעיף 12 במצטבר

אפשר לבטל לפי עילה בפרק ב׳ וגם לתבוע **פיצויי הסתמכות** לפי סעיף 12 (פרק 6). לא אפשר פיצויי קיום, כי החוזה בוטל.

8.4 שלד לפתרון שאלה

1. **האם נכרת חוזה?** פרק ב׳ נפתח רק אם נכרת (גמירת דעת אובייקטיבית + מסוימות).
2. **איזו עילה?** טעות / הטעיה / כפייה / עושק – התאימו לעובדות.
3. **בדקו את התנאים המצטברים** של העילה (טבלה 8.2) בנפרד.

4. **סעיף 20:** האם ניתנה הודעה בזמן סביר מהגילוי / סיום הכפייה?
5. **סעיף 21:** השבה לפי עשיית עושר; מה קיבל כל צד.
6. **אם התנאים לא מתקיימים:** חזרה לפרק א׳ – סעיף 12 (פיצויים), ובקיום – סעיף 39.

8.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "פרק ב׳ חל גם כשלא נכרת חוזה" – לא. הוא מניח חוזה שנכרת.
- "טעות בכדאיות מספיקה" – לא. טעות בכדאיות אינה עילה.
- "כפייה על ידי צד ג׳ מבטלת" – לא לפי סעיף 17 (הדר); חוזרים לתום לב.
- "עושק – כל עסקה בלתי משתלמת" – לא. נדרשת מידה בלתי סבירה וניצול.
- "אפשר לבטל בכל עת" – לא. זמן סביר מהגילוי (סעיף 20).
- "ביטול אינו מסוכן" – ביטול שלא כדין הוא הפרה.

8.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- פרק ב׳ סובייקטיבי ונפתח רק אחרי שנכרת חוזה.
- ארבע עילות: טעות (14), הטעיה (15), כפייה (17), עושק (18) – כל אחת בתנאים מצטברים.
- ביטול בהודעה בזמן סביר מהגילוי (20); השבה לפי עשיית עושר (21).
- ביטול שלא כדין = הפרה. אם התנאים לא מתקיימים – תום הלב (12) נשאר.

פרק 9

פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

9.1 מבוא: הקומה השלישית – תוכן החוזה

פרק ג׳ לחוק החוזים (חלק כללי) עוסק בתוכן החוזה. הנושא הראשון: **פרשנות**. המצב: כבר נכרת חוזה, שני הצדדים רוצים לקיימו, אך יש מחלוקת איך להבין אותו. בית המשפט מוסמך לפרש; בהמשך הוא מוסמך גם להתערב בתוכן (חוזה פסול ועוד).

שלוש שאלות הליבה בפרשנות	שתי הגישות
1. איך מסבירים את הטקסט? (נסיבות מול לשון)	**גישת היוצר** (נסיבות): מחפשים את מחשבות הצדדים ואומד דעתם. **גישת היצירה** (טקסט): לטקסט "חיים משלו" ומבינים אותו מתוך הלשון
2. האם מותר לסטות מלשון החוזה?	**פרשנות לשונית** מול **פרשנות תכליתית**
3. האם יש מקום לערכי החברה?	**תכלית אובייקטיבית** – ערכי החברה כשאין אומד דעת ברור

9.2 הנוסח המקורי של סעיף 25 ושיטת שני השלבים

§ סעיף — סעיף 25 (נוסח מקורי, 1973)

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה ובמידה שאינה משתמעת ממנו – מתוך הנסיבות.

הפסיקה פירשה את הנוסח כ**שיטת שני שלבים**: (1) לשון החוזה; (2) רק אם הלשון אינה ברורה – הנסיבות. הנסיבות לא נבדקות כשהלשון ברורה.

⚖ פסק דין — מדינת ישראל נ׳ חירם לנדאו (ע״א 450/82)

בחוזה פורטו רכיבי התערובת ובהם ביטומן, ונכתב ש"המדינה תשלם על ההתייקרויות לפי מדד הביטומן". כשהמחירים עלו בכל הרכיבים, חברה אחת דרשה הצמדה לכולם – בטענה ללשון רבים ("התייקרויות"), וזכתה. חירם לנדאו טענה שאותו חוזה מחייב אותה בהצמדה לכל הרכיבים; המדינה טענה שכלפי החברה האחרת הייתה אי-הבנה אך כאן שני הצדדים הבינו אותו דבר (הצמדה לביטומן בלבד). הכרעה בשיטת שני השלבים: הלשון ברורה ("התייקרויות" ברבים), ולכן אין צורך לעבור לנסיבות.

9.3 מהפכת אפרופים (1995)

⚖ פסק דין — מדינת ישראל נ׳ אפרופים שיכון ויזום (ע״א 4628/93)

המדינה, בעידוד בנייה, התחייבה לרכוש דירות מהקבלן ("רשת ביטחון") בחוזה אחיד עם לוח זמנים נוקשה; במבוא נכתב שמטרת הצדדים לעודד קבלנים לבנות מהר. המחיר ירד במקרים של איחור בבנייה או בהודעה; באזורי פיתוח אין התייחסות לאיחור בבנייה. אפרופים הודיעה בזמן שהיא רוצה שהמדינה תרכוש את כל הדירות, אך איחרה בסיום הבנייה בחמישה שבועות. המחלוקת: הפחתת המחיר.

הרכב של שלושה; **השופט ברק** הוביל את דעת הרוב וכתב "מאמר אקדמי" נגד שיטת השלבים.

✔ שורה תחתונה — חידושי ברק באפרופים

1. **ביטול שיטת שני השלבים:** אומד דעת הצדדים נלמד גם מהלשון וגם מהנסיבות (גישת היוצר).
2. **מותר לסטות מלשון החוזה:** פרשנות תכליתית.
3. **כשהשופט לא יודע מהו אומד הדעת:** פרשנות לפי ערכי החברה (תכלית אובייקטיבית).

בדיון הנוסף (ארגון מגדלי הירקות, 9 שופטים) נותרה התוצאה; **ריבלין וחשין** הסכימו עם גישת היוצר (נסיבות) אך התנגדו לשני החידושים האחרים – הסטייה מהלשון וערכי החברה.

9.4 תיקון 2011 וההתפתחות לאחריו

§ סעיף — סעיף 25(א) (אחרי תיקון 2011)

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

- **חל על חוזים שנעשו אחרי התיקון** בלבד.
- בפועל: אומד דעת הצדדים תוך בחינת הנסיבות, **עם בכורה ללשון** כשאומד הדעת משתמע מפורשות מהלשון.
- תיקונים נוספים בסעיף: **(ב)** חוזה הניתן לפירושים שונים – פירוש שמקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל; **(ב1)** חוזה שהיה לצד אחד עדיפות בעיצוב תנאיו – פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

⚖ פסק דין — ביבי כבישים נ׳ רכבת ישראל (ע״א 7649/18, 2019) – "לא כל החוזים נולדו שווים"

שתי גישות מבחינות לפי סוג הצדדים:

שופט	הצדדים	הפרשנות
אלכס שטיין	הצדדים השקיעו בניסוח	אומד דעת – **לשון החוזה**
	לא השקיעו בניסוח / פערי כוחות	ערכי החברה (יוצר תכליתי)
עופר גרוסקופף	מתוחכמים, שווי כוחות	אומד דעת – **לשון**
	לא מתוחכמים, שווי כוחות	אומד דעת – **נסיבות**
	פערי כוחות	**ערכי החברה** (תכלית אובייקטיבית)

פירוש לרעת המנסח (25(ב1))

⚖ פסק דין — אשר נ׳ פרוייקט גן העיר (ע״א 6271/95)

בפרוספקט נוצר רושם שגג הבריכה ציבורי, בחוזה הוחרג "הגג" מהרכוש המשותף. הדיירים טענו שזה גג אחר, הקבלן טען שגם הוא מוחרג. נפסק נגד הקבלן, כי הוא ניסח את החוזה – פירוש נגדו עדיף.

9.5 שלד לפתרון שאלה

1. **האם יש מחלוקת פרשנית?** חוזה קיים, שני צדדים רוצים לקיימו, והמחלוקת היא על ההבנה.
2. **מתי נעשה החוזה?** לפני/אחרי 2011 – קובע איזה נוסח.
3. **אומד הדעת:** האם הוא משתמע *במפורש* מהלשון? אם כן – לשון.
4. **נסיבות:** אם לא – בודקים נסיבות (מו״מ, תכלית, נוהגים).
5. **ערכי החברה:** אם אומד דעת לא נמצא (או פערי כוחות) – תכלית אובייקטיבית.
6. **כללי משנה:** 25(ב) – עדיף פירוש המקיים; 25(ב1) – פירוש נגד המנסח (חוזה אחיד).
7. **הדגישו את הגישה:** ברק (נסיבות + תכלית), ריבלין/חשין (נסיבות בלבד), שטיין/גרוסקופף (לפי סוג הצדדים).

9.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "אפרופים ביטלה את הלשון" – לא. היא ביטלה את שיטת השלבים; תיקון 2011 החזיר בכורה ללשון כשהאומד משתמע במפורש.
- "התיקון חל על כל חוזה" – לא. רק על חוזים שנעשו אחרי תאריכו.
- "ריבלין וחשין נגד הנסיבות" – לא. הם נגד הסטייה מהלשון וערכי החברה, לא נגד נסיבות.
- "פירוש נגד המנסח – תמיד" – רק כשהחוזה הניתן לפירושים שונים והייתה עדיפות בעיצוב.
- "אי-הבנה בין הצדדים אינה רלוונטית" – חירם לנדאו: כשהלשון ברורה ההכרעה ללשון.

9.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- פרשנות = ללמוד את אומד דעת הצדדים: יוצר (נסיבות) מול יצירה (לשון).
- עד 1995: שיטת שני שלבים (לנדאו). אפרופים: ברק – נסיבות + לשון, תכלית, ערכי החברה.
- תיקון 2011: אומד דעת מהחוזה ומהנסיבות; כשהוא מפורש בלשון – לשון.
- 25(ב) פירוש מקיים; 25(ב1) נגד המנסח; ביבי: שטיין/גרוסקופף מבחינים לפי סוג הצדדים.

פרק 10

חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

10.1 מבוא: כשהחוזה עצמו פגום

בפרק ב׳ (פגמים בכריתה) הנפגע טען שרצונו היה פגום ו**הוא** זכאי לבטל. כאן מדובר בחוזים שהפגם בהם אינו ברצון של צד אחד אלא ב**חוזה עצמו**: או שאינו אמיתי (**מראית עין**), או שמתנגד לחוק, למוסר או לתקנת הציבור (**חוזה פסול**). התוצאה היא **בטלות** – ללא צורך בהודעת ביטול – אך עם מנגנון גמיש של השבה ושיקולי צדק.

	בטלות (חוזה פסול / למראית עין)	ביטול (פרק ב׳)
מי מחליט	החוק: החוזה בטל מעיקרו; בית המשפט בוחן תוצאות	הנפגע, בהודעה (סעיף 20), בזמן סביר
מי יכול לטעון	כל מי שיש לו עניין; גם בית המשפט מיוזמתו	רק הנפגע
השבה	סעיף 31: שיקול דעת – אפשר לפטור, לחייב ואף להתנות אכיפה	סעיף 21: השבה הדדית לפי עשיית עושר

10.2 חוזה למראית עין (סעיף 13)

§ סעיף 13 — סעיף 13

חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

- **המשמעות:** הצדדים ערכו מסמך שאינו משקף את רצונם האמיתי (למשל כדי להסתיר נכסים מנושים או לרמות את הרשויות). החוזה **הגלוי** בטל כי אין בו גמירת דעת אמיתית.
- **צד שלישי תם לב מוגן:** מי שהסתמך על החוזה הגלוי והתנהל בתום לב (למשל קונה שרכש מהקונה הפיקטיבי) – לא יפגע.
- **החוזה הנסתר:** לעיתים מאחורי החוזה הפיקטיבי מסתתר חוזה אמיתי. הנטייה בפסיקה (בעקבות דעתו של ברק בדעת מיעוט בפרשת ביטון נ׳ מזרחי, שאומצה בגרומט נ׳ סרוסי) היא **לתת תוקף לחוזה הנסתר** כל עוד אינו פסול בעצמו.

! שים לב — שים לב

ההבחנה בין שני המושגים: **מראית עין** – החוזה אינו אמיתי (פגם ברצון המשותף); **חוזה פסול** – החוזה אמיתי אך אסור. כשחוזה למראית עין נעשה למטרה בלתי חוקית (עסקה פיקטיבית להעלמת מס) – שני הדינים נפגשים, ובפסיקה הוצעה גישת **"הפגם הכפול"** (הנדל, אילן נ׳ לוי).

10.3 חוזה פסול (סעיף 30)

§ סעיף — סעיף 30

חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.

שלושה "מקומות" של הפסלות	דוגמה
כריתה	כריתת חוזה בניגוד לדרישת חוק (חוזה של רשות ציבורית ללא חתימות הנדרשות)
תוכן	תוכן אסור: סחר בסמים; תניה הפוגעת בזכויות יסוד
מטרה	חוזה לגיטימי במהותו שנועד למטרה אסורה: חוזה להעלמת מס, מימון עבירה

- **שלושה סוגי אי-חוקיות:** בלתי חוקי (מנוגד לחוק), בלתי מוסרי, או סותר תקנת הציבור (ערכי יסוד של החברה).
- **"תקנת הציבור"** היא מושג פתוח שבית המשפט ממלא בתוכן: חופש העיסוק, שוויון, כבוד האדם. חוקי היסוד חלים גם על חוזים פרטיים (מכוח תקנת הציבור וסעיף 30).

דוגמה: תניית אי-תחרות

✎ דוגמה — תניית אי-תחרות

ראובן ושמעון ניהלו עסק משותף בתחום הטקסטיל והסכימו שאחרי סיום פעילותם יהיה שמעון מנוע מלהקים עסק מתחרה ל-5 שנים. תניה כזו פוגעת בחופש העיסוק ולכן **בית המשפט רשאי להתערב בתוכן החוזה** – לבטל את התניה או לשנותה (לצמצם בזמן/במרחב) כדי להתאימה לתקנת הציבור. אין הדבר תלוי בכך שהניסוח חד-צדדי.

10.4 התוצאות: בטלות והשבה (סעיף 31)

§ סעיף — סעיף 31 – סעד מן הצדק

בניגוד לבטלות רגילה (שמחייבת השבה הדדית), בחוזה פסול **בית המשפט רשאי לפי שיקול דעתו ומטעמי צדק**: לפטור את הצדדים מהשבה (כשזה צודק), לחייב בהשבה, ואף להורות על קיום החוזה כשהצדדים כבר החלו בביצועו.

מצב	סמכות בית המשפט (סעיף 31)
הצדדים לא החלו בביצוע	החוזה בטל; אין אכיפה. אין מה להשיב
הצדדים החלו בביצוע	שיקול דעת: פטור מהשבה, חיוב בהשבה, או קיום החוזה (בתנאים שיקבע) משיקולי צדק
צד "מפר החוק" מול צד תם	בית המשפט שוקל את מידת האשם והתועלת הציבורית

⚖ פסק דין — העלמת מס: חוזה בטל – אבל שיקולי צדק

ראובן ושמעון התקשרו בחוזה וסיכמו להעלים מס. **החוזה בטל** ואי אפשר לאכוף אותו כמות שהוא. ואולם בית המשפט רשאי, על בסיס שיקולי צדק, להורות על קיום החוזה **רק אם הצדדים כבר החלו בביצועו**; אם עוד לא התחילו – אין סמכות להורות על קיום. אין זה נכון שהוא "מוגבל רק לפטור מהשבה".

⚖ פסק דין — לוין נ׳ לוין (ע"א 3833/93) – גם שיקולי צדק כוללים צדדים שלישיים

הסכם בין בני זוג אסר להציג את החוזה בבית משפט. בית המשפט שקל לא רק את הצדדים אלא את **הילדים והציבור**. כך גם בסעיף 31: בוחנים את השפעת החוזה על החברה כולה, לא רק על הצדדים.

⚖ פסק דין — חוזה של רשות ציבורית ללא חתימת הגזבר

על פי פקודת העיריות, חוזה של עירייה מחייב חתימות ראש העירייה והגזבר. עירייה התקשרה, החברה ביצעה את חלקה, והעירייה טוענת שהחוזה בטל כי חסרה חתימת הגזבר. זה חוזה בלתי חוקי, אך **אין בטלות אוטומטית עיוורת**: בית המשפט נוקט שיקול דעת רחב בהשבה (סעיף 31), ובכך מגן על הצד שביצע בתום לב ועל כספי הציבור.

10.5 שלד לפתרון שאלה

1. **האם החוזה אמיתי?** אם נועד להסתיר – מראית עין (13): הגלוי בטל; הנסתר – האם תקף?
2. **האם יש פסלות?** כריתה / תוכן / מטרה; חוק, מוסר או תקנת הציבור.
3. **התוצאה:** בטלות. אין צורך בהודעה.
4. **סעיף 31:** האם החלו בביצוע? שיקולי צדק (כולל צדדים שלישיים): פטור מהשבה / חיוב בהשבה / אכיפה.
5. **צד שלישי תם לב:** מוגן (13 סיפא).

10.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "חוזה פסול – אין שום סעד" – לא. סעיף 31 נותן שיקול דעת: השבה, פטור, ואף אכיפה אם הוחל בביצוע.
- "בית המשפט יכול לאכוף חוזה פסול גם לפני ביצוע" – לא. רק אם הצדדים החלו בביצוע.
- "חוקי היסוד אינם חלים על חוזים פרטיים" – לא. הם חלים דרך תקנת הציבור וסעיף 30.
- "מראית עין = חוזה פסול" – לא. הראשון חוזה לא אמיתי, השני אמיתי אך אסור.
- "צד שלישי תם לב נפגע מבטלות החוזה" – לא; מוגן.

10.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- סעיף 13: מראית עין – בטל; צד שלישי תם לב מוגן; החוזה הנסתר יכול להיות תקף.
- סעיף 30: כריתה/תוכן/מטרה בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או נגד תקנת הציבור – בטל.
- סעיף 31: שיקול דעת מטעמי צדק – פטור/חיוב בהשבה ואף קיום, רק אם הוחל בביצוע.
- תניית אי-תחרות: בית המשפט רשאי לבטל או לשנות (תקנת הציבור וחופש העיסוק).

פרק 11

חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982)

11.1 מבוא: למה חוק מיוחד

החוזה הקלאסי מניח שני צדדים שמנהלים משא ומתן. במציאות רוב החוזים היומיומיים (ביטוח, בנק, תקשורת, חניון, כרטיס טיסה) נכתבים מראש בידי צד אחד ומוצעים לקוחות במתכונת "קח או עזוב". לכן חוקק **חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982**, שנועד להגן על לקוחות מפני ניצול כוח המיקוח העודף של הספק.

11.2 מהו חוזה אחיד (סעיף 2)

✦ הגדרה — חוזה אחיד

נוסח של חוזה שתנאיו (כולם או חלקם) נקבעו מראש בידי צד אחד (הספק) כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין לקוחות בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, בלי משא ומתן אמיתי עליהם.

- **העיקר:** "תנאים קבועים מראש" + "ללא מו"מ" + "לקוחות רבים". הכותרת "חוזה אחיד" אינה חשובה.
- **דוגמה מהמבחן:** נגר מציג שולחנות בחלון הראווה, ועל כל שולחן מעטפה "תנאי העסקה – נא לעיין לפני הרכישה", ובה תנאים כלליים. זהו חוזה אחיד.

11.3 תנאי מקפח וחזקות הקיפוח (סעיפים 3–4)

§ סעיף — סעיף 3 – תנאי מקפח

תנאי בחוזה אחיד שיש בו, **בהתחשב בכל תנאי החוזה ובנסיבות העניין**, משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק – הוא תנאי מקפח.

§ סעיף — סעיף 4 – חזקות הקיפוח

החוק מונה רשימת תנאים ש**חזקה** שהם מקפחים (נטל ההוכחה מוטל על הספק להפריך): למשל **פטור או הגבלה של אחריות הספק** (ובמיוחד לנזק גוף), זכות ביטול/דחייה חד-צדדית של הספק, שינוי חד-צדדי של המחיר, תניית שיפוט/ברירת דין בעלת נפקות לרעת הלקוח.

	תנאי מקפח (3)	חזקת קיפוח (4)
מי מוכיח	הלקוח מוכיח שהתנאי מקפח	**הספק** צריך להוכיח שהתנאי הוגן

מהי "חזקה" = בטלות?	קיפוח או יתרון בלתי הוגן, לפי נסיבות –	תנאים מוגדרים בחוק (פטור מאחריות וכד׳) לא אוטומטי: הספק יכול לשכנע שההסדר הוגן

! שים לב — שים לב

"חזקה" אינה "בטלות". סעיף פטור מאחריות בחוזה אחיד נחשב מקפח **בחזקה**, והספק יכול להוכיח שהוא הוגן. לא כל תניית שיפוט זר מקפחת בהכרח – אפשר להוכיח אחרת (למשל ראובן, איש עסקים, מול חברת אינטרנט עם תניית דיני קליפורניה).

11.4 הסעדים והערכאות (סעיפים 19, 23)

גורם	סמכות
בית הדין לחוזים אחידים	לבטל או לשנות תנאי מקפח **באופן כללי** (לכל הלקוחות), ללא קשר למקרה פרטי
בית משפט רגיל (סעיף 19)	בהליך **פרטני** בין ספק ללקוח – יכול לבטל או לשנות תנאי מקפח לגבי הצדדים לאותו הליך
סעיף 23	סייגים: תנאים מסוימים אינם נבחנים, כגון **מחיר הטובין או השירות** (התמורה הכספית) ככלל

✎ דוגמה — דוגמה: הנגר והשולחן

שולחן נפגע בהובלה בתאונה שגרם המוביל. בתנאי המעטפה: "דני אינו אחראי לגורל השולחן במהלך ההובלה". זהו **חוזה אחיד** ו**תניה הפוטרת מאחריות = חזקת קיפוח**. בית המשפט מוסמך לבטל את התניה, ואז חלים הכללים הרגילים. הניסוח "הוסכם במפורש" אינו מספיק; ההסכמה היא "קח או עזוב".

✎ דוגמה — דוגמה: מכון כושר

בחוזה אחיד נכתב: "לראובן אין אחריות לנזק גוף שייגרם למשתתפים – מכל סיבה שהיא". פטור גורף מאחריות לנזק גוף הוא **חזקת קיפוח**; הסעיף אינו בטל אוטומטית, והספק רשאי להוכיח שההסדר הוגן.

11.5 חוזה אחיד ופרק ב׳ (פגמים בכריתה)

חוק החוזים האחידים **אינו מחליף** את חוק החוזים הכללי. גם חוזה אחיד ניתן לביטול **בכל העילות של פרק ב׳** (טעות, הטעיה, כפייה, עושק), בכפוף לתנאים. בנוסף, חל עקרון הפרשנות **נגד המנסח** (סעיף 25(ב1) לחוק החוזים הכללי, ראו פרק 9).

11.6 שלד לפתרון שאלה

1. **האם חוזה אחיד?** תנאים קבועים מראש בידי ספק, לקוחות רבים, בלי מו״מ.
2. **האם התנאי מקפח?** בדקו את סעיף 3 ואת רשימת החזקות בסעיף 4.

3. **נטל ההוכחה:** בחזקה – על הספק.
4. **סעד:** בית הדין לחוזים אחידים (כללי) או בית משפט (פרטני, 19).
5. **סייג:** סעיף 23 (מחיר, לרוב).
6. **במקביל:** פרק ב׳, סעיף 12/39, ופרשנות נגד המנסח.

11.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "תנאי מקפח בטל אוטומטית" – לא. בית המשפט או בית הדין **מוסמכים** לבטל או לשנות.
- "חזקה = בטלות" – לא. נטל ההוכחה עובר לספק.
- "חוזה אחיד חייב להיות בכתב וכותרתו חוזה אחיד" – לא. מה שקובע הוא אופיו.
- "אין אפשרות לבטל חוזה אחיד בפרק ב׳" – לא. אפשר, בכל העילות.
- "כל תניית שיפוט זר בלתי חוקית" – לא. ניתן להוכיח שהיא הוגנת (איש עסקים).
- "מחיר מקפח" – ככלל, התמורה אינה נבחנת כתנאי מקפח (סעיף 23).

11.8 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- חוזה אחיד: תנאים קבועים מראש, לקוחות רבים, בלי מו״מ (סעיף 2).
- תנאי מקפח (3); חזקות קיפוח (4) – הנטל על הספק; פטור מאחריות הוא חזקה.
- בית הדין לחוזים אחידים – ביטול כללי; בית משפט – פרטני (19); סייגים (23).
- פרק ב׳ ופרשנות נגד המנסח חלים גם בחוזה אחיד.

פרק 12

חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

12.1 מבוא: חוזה שתוקפו או ביצועו תלויים באירוע עתידי

לעיתים צדדים מסכימים שחוזה יחייב, או יפסיק לחייב, **רק אם יתרחש אירוע עתידי לא ודאי**: אישור רשויות התכנון, קבלת הלוואה, זכייה במכרז. זהו **חוזה על תנאי**. התנאי אינו חלק מהתנאים לכריתה (גמירת דעת ומסוימות) – אלה כבר התקיימו; התנאי קובע את **גורל החיוב**.

	תנאי מתלה	תנאי מפסיק
מה הוא עושה	החוזה (או חיוב בו) מתחיל לחייב רק כשהתנאי מתקיים	החוזה חל מיד, אך **פוקע** כשהתנאי מתקיים
דוגמה	"העסקה טעונה אישור רשויות התכנון"	"החוזה בתוקף עד שלא תתקבל הלוואה"
עד שהתנאי מתברר	מצב ביניים: הצדדים מחויבים להימנע מפעולה שתסכל את התנאי	החוזה מחייב; מפסיק אם התנאי מתקיים
אם התנאי לא מתקיים	החוזה אינו מתחיל לחייב (בטל / פוקע)	החוזה ממשיך

✎ דוגמה — דוגמה: בניית בניין

ראובן בעל מקרקעין, שמעון קבלן. בכתב נקבע: "העסקה טעונה אישור של רשויות התכנון. שמעון יעשה כל שביכולתו לקבל אישור בנייה". שמעון פנה מספר פעמים, והרשויות לא אישרו. **נכרת חוזה על תנאי מתלה; התנאי לא התקיים והחוזה בטל (פוקע).** אין כאן טעות או סיכול, והחוזה גם נכרת (יש גמירת דעת ומסוימות); פשוט התנאי לא התקיים.

12.2 חובת תום הלב בתנאי: מי שסיכל אינו יכול להסתמך

✔ שורה תחתונה — הכלל

צד אשר **פעל לסיכולו של תנאי** בחוזה (מנע את קיומו) – **ככלל אינו זכאי להסתמך על אי-קיומו**. מי שהכשיל את התנאי בחוסר תום לב לא ירוויח מכך. הכלל נגזר מתום הלב בקיום (סעיף 39) ומעקרון שאין אדם נהנה מעוולתו.

- **דוגמה:** קונה שהתנה את העסקה בקבלת הלוואה, ולא הגיש בקשה להלוואה כדי להיחלץ – אינו רשאי לטעון שהתנאי לא התקיים.
- **לא כל סיכול:** רק מניעה שאינה בתום לב; אי-קיום שנבע מנסיבות חיצוניות אינו סיכול התנאי על ידי צד.

12.3 הבחנות חשובות

מושג	מה הוא
חוזה על תנאי	החוזה נכרת; חיוב או תוקף תלויים בתנאי עתידי
חוזה שטרם נכרת	אין גמירת דעת/מסוימות – בטכניקת זיכרון דברים, למשל "בכפוף לחוזה מפורט"
סיכול (תרופות 18)	אירוע חיצוני שהפך את הקיום לבלתי אפשרי – הגנת המפר, לא תנאי בחוזה
פגם בכריתה	טעות/הטעיה וכד׳ – ביטול בפרק ב׳

12.4 שלד לפתרון שאלה

1. **האם נכרת חוזה?** גמירת דעת + מסוימות (פרקים 2–4).
2. **האם יש תנאי?** מתלה או מפסיק; מה לשון התנאי.
3. **האם התנאי התקיים?** אם לא – תוצאה לפי סוג התנאי.
4. **האם צד סיכל את התנאי?** אם בחוסר תום לב – אינו יכול להסתמך על אי-קיומו.
5. **דחה?** אם לא מדובר בתנאי אלא בסיכול או בפגם – נתב לפרק המתאים.

12.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "אם התנאי לא התקיים – מעולם לא נכרת חוזה" – לא. החוזה נכרת, אך אינו מחייב/פוקע.
- "אי-קיום תנאי = טעות" – לא. טעות היא פגם ברצון בעת הכריתה.
- "אי-קיום תנאי = סיכול" – לא. סיכול הוא הגנת מפר מכוח החוק; התנאי הוסכם בחוזה.
- "מי שמנע קיום תנאי רשאי להסתמך על אי-קיומו" – לא ככלל.

12.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- חוזה על תנאי: נכרת כדין; גורל החיוב תלוי באירוע עתידי.
- תנאי מתלה – מתחיל לחייב עם התקיימות התנאי; תנאי מפסיק – פוקע עם התקיימות התנאי.
- צד שסיכל את התנאי אינו יכול ככלל להסתמך על אי-קיומו.
- אל תבלבלו בין תנאי, סיכול (18) ופגם בכריתה (פרק ב׳).

פרק 13

חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

13.1 מבוא: חריג ליחסיות החוזה

הכלל: חוזה מקים זכויות וחובות **רק בין צדדיו** (עקרון יחסיות החוזה, privity). **חוזה לטובת צד שלישי** הוא חריג: שני צדדים מתקשרים בהסכם שבו אחד מהם (המבטיח, "החייב") מתחייב לתת תועלת לאדם שאינו צד לחוזה (ה**מוטב**), והמוטב רוכש **זכות תביעה ישירה**.

תפקיד	מי
המבטיח (החייב)	הצד שמתחייב לטובת המוטב
הנושה (המתנה)	הצד שהחיוב נעשה לבקשתו, זה שקיבל את ההבטחה
המוטב	הצד השלישי – נהנה מהחיוב ויכול לתבוע

✎ דוגמה — דוגמאות

ביטוח חיים: המבוטח משלם פרמיה לחברת הביטוח, והמוטב (בן/בת הזוג) זכאי לתבוע את הסכום. **חוזה מכר:** ראובן קונה מסחורה ממוכר וביקש שהסחורה תימסר לשמעון. **ערבות/התחייבות לטובת ילד** במסגרת הסכם.

13.2 התנאי: כוונה להקנות זכות

§ סעיף — סעיף 34

חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת צד שלישי מקנה לצד השלישי את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו.

- **לא די ב"הנאה" מהחוזה:** אדם שמפיק תועלת עקיפה (למשל שכן שנהנה מחוזה גינון) אינו מוטב.
- **הכוונה נלמדת מהחוזה ומהנסיבות** – פרשנות לפי אומד דעת הצדדים (ראו פרק 9).
- **המוטב רשאי לתבוע בעצמו** את קיום החיוב.

13.3 שינוי וביטול הזכות; טענות החייב

שאלה	הדין (סעיפים 34–38)
עד מתי הצדדים רשאים לשנות או לבטל את זכות המוטב?	כל עוד המוטב לא הודיע על הסכמתו או הסתמך על הזכות – אז **הזכות מתגבשת** ואין לשנותה

אילו טענות עומדות לחייב כלפי המוטב?	כל הטענות שהיו לו כלפי הנושה (כגון הפרה, פגם בכריתה) – המוטב אינו עדיף על הנושה
מה ההבדל מהמחאת זכות?	בהמחאה הנושה מעביר זכות **קיימת** שלו; במוטב נוצרת זכות **חדשה** בחוזה עצמו לטובת הצד השלישי

! שים לב — שים לב

המוטב **אינו צד** לחוזה: הוא אינו חייב כלפי הצדדים, ואינו נוטל על עצמו חובות. הוא רוכש זכות, וזכותו מושפעת מהחוזה שהיא נגזרת ממנו.

13.4 שלד לפתרון שאלה

1. **זיהוי:** מי המבטיח, מי הנושה ומי המוטב.
2. **כוונה להקנות זכות?** (34) – מתוך החוזה והנסיבות; לא הנאה בלבד.
3. **תביעה:** המוטב רשאי לתבוע את קיום החיוב.
4. **שינוי/ביטול:** האם המוטב הודיע על הסכמתו או הסתמך? אם כן – הזכות התגבשה.
5. **טענות החייב:** כל מה שהיה לו מול הנושה.
6. **הבחנה:** האם זו המחאת זכות ולא מוטב.

13.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "כל מי שנהנה מהחוזה הוא מוטב" – לא. נדרשת כוונה להקנות זכות.
- "המוטב צד לחוזה" – לא.
- "אפשר תמיד לשנות את זכות המוטב" – לא. אחרי הסכמה/הסתמכות היא מתגבשת.
- "המוטב נקי מטענות החייב" – לא. החייב שומר טענותיו כלפי הנושה.
- "חוזה לטובת צד ג׳ = המחאת זכות" – לא.

13.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- חריג ליחסיות החוזה: המוטב רוכש זכות תביעה ישירה (34).
- נדרשת כוונה להקנות זכות; הנאה בלבד אינה מספיקה.
- זכות המוטב מתגבשת עם הסכמתו/הסתמכותו; עד אז אפשר לשנות.
- החייב שומר כל טענות שהיו לו כלפי הנושה; אין זהות להמחאת זכות.

פרק 14

הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

14.1 מבוא: הקומה האחרונה – הפרה ותרופות

החלק האחרון בקורס עוסק בחוזה שכבר נכרת ונתקיים ובו מופרות התחייבויות. הדין העיקרי הוא **חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970**. אבל סעיף אחד נשאר בחוק החוזים הכללי: **סעיף 39 – תום לב בקיום חוזה**.

§ סעיף — הגדרות ועקרונות (חוק התרופות)

- **הפרה** – מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה.
- **נפגע** – מי שזכאי לקיום החוזה שהופר.
- הופר החוזה, הנפגע זכאי לתבוע **אכיפה** או **לבטל** את החוזה, וזכאי ל**פיצויים** בנוסף לאחת התרופות האמורות או במקומן.

14.2 סעיף 12 מול סעיף 39: שני סעיפי תום לב

	סעיף 12	סעיף 39
שלב	לפני כריתת החוזה (משא ומתן)	בקיום חיוב ובשימוש בזכות
תרופות	פיצויי הסתמכות/קיום (בהתאם לנסיבות); אכיפה במקרים מיוחדים	**סל רחב:** פיצויי קיום, אכיפה, ביטול
דוגמה	ספקטור נ' צרפתי	ראובן נ' סופר-דוש

⚖ פסק דין — ראובן נ' סופר-דוש (ע"א 8336/17, 2022)

מבצע "אחד פלוס אחד, הזול מביניהם". לקוח רכש שלושה מוצרים במחירים 50, 50, 10, והייתה מחלוקת על סדר חישוב המבצע. נפסק שעל הספק לבצע את הבחירה באופן שבו היה הלקוח בוחר, מכוח **תום הלב בקיום חוזה (סעיף 39)**.

14.3 שלוש הגנות למפר

הגנה	מקור	מהות
1. עמידה דווקנית על זכויות	פסיקה (תום לב)	גם הנפגע שתובע תרופות חייב לנהוג בתום לב; לא ינצל טעות פעוטה

2. אשם תורם	פסיקה	הנפגע תרם לנזק – מחלקים אחריות
3. פטור בשל אונס/סיכול	סעיף 18 לחוק התרופות	נסיבות שהמפר לא ידע/לא צפה ולא יכול היה למנוע, וקיום בלתי אפשרי או שונה מהותית

⚖ פסק דין — ג׳רבי נ׳ בן דוד – עמידה דווקנית

פסק דין חייב את ג׳רבי לשלם 3,000 דולר. בפשרה נקבע: אם ישלם עד 15 בפברואר – 2,500 דולר; אם לא – 3,000 (פיצוי מוסכם 500). ביום האחרון הגיע למשרד עורך הדין, שלא נמצא, והשאיר שיק של 2,000 דולר – טעה בסכום. כעבור ימים הבין, חזר לתקן, אך בן דוד דרש את מלוא 3,000. העליון: ג׳רבי הפר, אך **גם הנפגע חייב בתום לב**; עמידה דווקנית על הזכות לתרופה בנסיבות כאלה מנוגדת לתום הלב.

סיכול (סעיף 18 לחוק התרופות)

§ סעיף — סעיף 18(א)

היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם – לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

שלושה תנאים מצטברים: (1) נסיבות מסכלות – קיום בלתי אפשרי או שונה מהותית (מחלה, שריפה, פגעי טבע); (2) המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת/לצפות בעת הכריתה; (3) המפר לא יכול היה למנען.

- **גישה מסורתית נוקשה:** פגעי טבע, פטירה, שריפה ואפילו מלחמה – ניתנים לצפייה. כץ נ׳ ניצחוני מזרחי (ע״א 715/78) – מלחמת יום הכיפורים בישראל צפויה.
- **רגב נ׳ משרד הביטחון (ע״א 6328/97, 2000):** אמרת אגב – הגישה נוקשה מדי; יש קרבה בין סיכול לבין תום לב בקיום (סעיף 39): מתקשר שעומד על ביצוע דווקני למרות שינוי מהותי אינו נוהג בתום לב. בפועל אין פסק דין עליון שהכיר בסיכול מאז.
- **בן אבו נ׳ מדינת ישראל (מחוזי):** סגר בשטחים באותה תקופה לא היה צפוי – סיכול הוכר, אך כל מקרה לגופו. כך גם בקורונה: אין כלל גורף.

✔ שורה תחתונה — תוצאות הסיכול – הגנה חלקית

1. אין אכיפה ואין פיצויי קיום.
2. הנפגע עדיין **רשאי לבטל** את החוזה.
3. בית המשפט **רשאי** (שיקול דעת) להורות על השבה הדדית ועל **פיצויי הסתמכות** (סעיף 18(ב)): אם נראה לו צודק בנסיבות.

14.4 הפרה צפויה והפרה יעילה

§ סעיף — סעיף 17 לחוק התרופות – הפרה צפויה

גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות העניין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות גם לפני המועד שנקבע לקיום, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד.

גם כאן חלה חובת תום הלב על הנפגע: אם התברר שהצד השני לא יקיים והנפגע לא ניסה לצמצם נזקים, זו עילה להפחתה (אשם תורם).

✎ דוגמה — דוגמה: הפרה יעילה

ראובן קנה נכס ב-90 (שווי שוק 110) והתחייב למכור לשמעון ב-100. לאה מציעה לראובן 120. **אפשרות א׳:** לסרב ולקיים לשמעון – רווח 10. **אפשרות ב׳ (הפרה יעילה):** למכור ללאה – רווח 30; שמעון יתבע פיצוי קיום של 10 (שווי השוק 110 פחות המחיר 100); רווח נטו של ראובן 30−10=20 – משתלם להפר. הדין האמריקני מקבל את זה. בישראל **אכיפה** היא התרופה המרכזית, והפרה יעילה מסכלת אותה.

⚖ פסק דין — אדרס נ׳ הרלו אנד ג׳ונס (ד״נ 20/82)

חברה גרמנית התחייבה לספק ברזל לחברה ישראלית, המחיר זינק, היא הפרה ומכרה לאחר ברווח. לאחר חודשים המחיר ירד והחברה הגרמנית ביקשה לספק. הישראלית לא עמדה בתנאי הפיצויים (אין נזק ממוני, אין עוגמת נפש לתאגיד, 11א תקף רק בביטול, אין פיצוי מוסכם) ותבעה **עשיית עושר ולא במשפט** – את רווחי המפר. על חודו של קול: הנפגע רשאי לבחור בין תרופות חוק החוזים לבין עשיית עושר. יש אלמנט ענישה: מונע הפרה יעילה.

14.5 שלד לפתרון שאלה

1. **האם יש הפרה?** (מעשה או מחדל בניגוד לחוזה; גם הפרה צפויה).
2. **הגנות:** עמידה דווקנית? אשם תורם? סיכול (שלושה תנאים)?
3. **סעיף 39:** האם אחד הצדדים לא נהג בתום לב בקיום / בשימוש בזכות?
4. **תוצאה:** איזו תרופה נשארת (ביטול, השבה, הסתמכות).
5. **הפרה יעילה:** אם כדאי למפר להפר – אדרס.

14.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "סיכול פוטר מכל תרופה" – לא. הוא חוסם אכיפה ופיצויי קיום, אך הנפגע יכול לבטל, ויכול להימצא פיצויי הסתמכות/השבה.
- "כל מלחמה/מגפה היא סיכול" – לא. כל מקרה לגופו; הפסיקה נוקשה.
- "תום הלב מחייב רק את המפר" – לא. גם הנפגע (ג׳רבי).
- "סעיף 12 וסעיף 39 זהים" – לא. הסעד רחב יותר בסעיף 39.
- "הפרה יעילה אסורה" – לא בהכרח; בישראל נשאר אכיפה, והתשובה בעשיית עושר (אדרס).

14.7 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- סעיף 39 – תום לב בקיום; סל תרופות רחב מסעיף 12.
- שלוש הגנות: עמידה דווקנית, אשם תורם, סיכול (3 תנאים).
- סיכול – הגנה חלקית: אין אכיפה/קיום; יש ביטול, ושיקול דעת להשבה/הסתמכות.
- הפרה צפויה (17) והפרה יעילה (אדרס): רווחי מפר דרך עשיית עושר.

פרק 15

תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

15.1 מפת התרופות

הופר החוזה, הנפגע זכאי ל**אכיפה** או ל**ביטול**, ובנוסף לאחת מהן או במקומן – ל**פיצויים**. בישראל **האכיפה היא התרופה המרכזית** והכלל; יתר התרופות הן חלופה.

15.2 אכיפה: כלל ו-4 חריגים

§ סעיף — סעיף 3 לחוק התרופות

הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: (1) החוזה אינו בר-ביצוע; (2) אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי; (3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל; (4) אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

חריג	מהות	הערה
(1) אינו בר-ביצוע	אי אפשר לקיים בדיוק	אכיפה בקירוב (סעיף 4): **אייזמן נ׳ קדמת עדן** – דירת 3 חדרים לא קיימת, יקבל 4 חדרים וישלים כסף
(2) עבודה/שירות אישי	כפייה לעבוד או לקבל שירות אישי	ערכי החברה; נפוץ בדיני עבודה
(3) פיקוח בלתי סביר	הליכים אין-סופיים	יעדיף ביטול, פיצויים או מינוי נושא תפקיד
(4) בלתי צודקת	סעיף סל	**החריג צר מאוד** – הכלל הוא אכיפה. שיקולי צדק כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור (לוין נ׳ לוין: הסכם בין בני זוג שאסור להציגו בבית משפט – שיקול ילדים)

§ סעיף — סעיף 4

בית המשפט רשאי להתנות את אכיפת החוזה בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם או בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה.

15.3 ביטול בשל הפרה (סעיפים 6–7)

ההבדל המהותי מפרק ב׳: בפרק ב׳ הנפגע טוען שלא רצה להיכנס לחוזה; כאן **היה חוזה והוא הופר**, ולכן המבטל **אינו משחרר את המפר** מאחריות להפרה. אפשר לבטל ובנוסף לתבוע פיצויי קיום.

§ סעיף — סעיף 6 – הפרה יסודית

"הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן – אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.

סוג	הגדרה
יסודית מסתברת	אדם סביר לא היה מתקשר אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה
יסודית מוסכמת	הוסכם בחוזה שהפרת סעיף מסוים יסודית. **סעיף ספציפי – תקף.** רשימת סל ("הפרת הסעיפים 2–8 יסודית") – תניה גורפת, תקפה רק אם הייתה סבירה בעת הכריתה (שלום נ׳ מוטה: התניה הגורפת לא תקפה, אך הסעיף עצמו אינו בטל)

	הפרה יסודית	הפרה לא יסודית
מתי מבטלים	מיד, בלי ארכה	קודם ארכה סבירה למפר; רק אם לא קיים בתוכה – ביטול
התערבות בית המשפט	אין (ביטול שמור לנפגע)	כן, משיקולי צדק (למשל אשם תורם)
ביטול שלא כדין	הנפגע הופך למפר	הנפגע הופך למפר

§ סעיף — סעיף 7(ג) – חוזה הניתן להפרדה

הופר אחד מחלקי חוזה הניתן להפרדה – ביטול החלק שהופר בלבד; ואם הייתה הפרה יסודית של כלל החוזה – אפשר לבטל את החלק או את כולו.

15.4 שלד לפתרון שאלה

1. **הפרה:** האם התקיימה הפרה, ומה הצד שנפגע.
2. **אכיפה:** האם אחד מארבעת החריגים בסעיף 3 (אכיפה בקירוב?).
3. **ביטול:** יסודית או לא; אם לא – נתנו ארכה?
4. **פיצויים:** בנוסף לאכיפה/ביטול – קיום; ובאדרס – רווחי המפר.
5. **הגנות:** עמידה דווקנית, אשם תורם, סיכול (פרק 10).

15.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "אכיפה היא חריג" – לא. היא הכלל; חריג הצדק מצומצם מאוד.
- "ביטול בשל הפרה משחרר את המפר" – לא. אפשר לתבוע גם פיצויי קיום.
- "תניה גורפת בטלה כולה" – לא; רק התניה הגורפת, והסעיף נשאר (שלום נ׳ מוטה).
- "הפרה לא יסודית מאפשרת ביטול מיידי" – לא. נדרשת ארכה.
- "ביטול בטעות לא מסוכן" – לא. ביטול שלא כדין = הפרה.

15.6 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- אכיפה היא הכלל; ארבעה חריגים (3); אכיפה בקירוב (4).
- ביטול בשל הפרה: יסודית – מיד; לא יסודית – אחרי ארכה; ביטול שלא כדין = הפרה.
- ביטול בשל הפרה לא משחרר את המפר; אפשר פיצויים בנוסף.
- תניה גורפת על הפרות יסודיות – לא תקפה אלא אם סבירה.

פרק 16

פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

16.1 מבוא: התרופה הכספית

אחרי שהוכרה הפרה, התרופה הכספית המרכזית היא **פיצויים**; ולצידה, אחרי ביטול, **השבה**. הדין הכללי: חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. בפרק 6 למדנו פיצויים בגין חוסר תום לב במו"מ; כאן – פיצויים בגין **הפרת חוזה**.

סעיף	נושא
9	השבה אחרי ביטול: כל צד משיב מה שקיבל; ואם בלתי אפשרי – שוויו
10	פיצויי ציפייה + מבחן הצפיות
11	פיצוי אחרי ביטול: הפרש מחיר (החוזה מול השוק), ללא הוכחת נזק
13	נזק שאינו ממוני (עוגמת נפש)
14	חובת הקטנת הנזק
15	פיצויים מוסכמים

16.2 פיצויי ציפייה והצפיות (סעיף 10)

§ סעיף — סעיף 10

הנפגע זכאי לפיצוי בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה, **ובלבד שהנזק הוא תוצאה מסתברת** של ההפרה, **שהמפר ראה או היה עליו לראות מראש בעת כריתת החוזה** (מבחן הצפיות).

- **מטרה (אינטרס הקיום):** להעמיד את הנפגע במצב שבו היה אילו קוים החוזה.
- **הצפיות נבחנת בעת הכריתה** (לא בעת ההפרה): המפר אחראי רק לנזק שצפה או היה עליו לצפות כתוצאה מסתברת.
- **סיבתיות:** הנזק צריך להיגרם עקב ההפרה.

✎ דוגמה — דוגמה מספרית

קבלן התחייב למסור דירה ב-1.1 ברווח צפוי של 30,000 למוכר החוזר. הוא איחר ב-3 חודשים. הנפגע דרש שכר דירה זמני (10,000) והפסד רווח (5,000). אם שניהם נזק שהקבלן צפה בעת הכריתה – הם בני פיצוי. הפסד משני בלתי צפוי (נטילת הלוואה יקרה במיוחד) – ייתכן שלא.

16.3 פיצוי לאחר ביטול (סעיף 11) והשבה (סעיף 9)

	תוכן
סעיף 11	אחרי ביטול בשל הפרה: הנפגע זכאי להפרש בין המחיר החוזי לבין מחיר השוק (בעת הביטול) – **ללא הוכחת נזק**
סעיף 9	אחרי ביטול כל צד משיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה; אם אי אפשר – משלם את שוויו
אדרס נ' הרלו	נפגע רשאי לבחור גם פיצוי לפי דיני עשיית עושר – רווחי המפר מההפרה (ראו פרק 10)

✎ דוגמה — דוגמה: הפרש מחיר

מוכר התחייב לספק ברזל ב-100 לטון; בעת הביטול מחיר השוק 130. הנפגע זכאי ל-**30** לטון לפי סעיף 11, בלי להוכיח נזק פרטני. אם קנה חלופה ב-140 בפועל – ייתכן שיתבע לפי סעיף 10 את ההפרש בפועל.

16.4 נזק לא ממוני וחובת הקטנת הנזק

- **סעיף 13:** פיצוי על נזק שאינו ממוני (עוגמת נפש) בנסיבות מתאימות. **לתאגיד אין עוגמת נפש** – ולכן בפרשת אדרס לא עמד תאגיד בסעיף זה.
- **סעיף 14 – הקטנת נזק:** הנפגע חייב לנקוט אמצעים סבירים להקטין את נזקו. נזק שהיה אפשר להימנע ממנו באמצעים סבירים – אינו בר פיצוי (אחריות משותפת).
- **הקשר לתום הלב:** נפגע שהמתין ולא צמצם נזק (למשל אחרי הפרה צפויה) – ייפגע הפיצוי.

16.5 פיצויים מוסכמים (סעיף 15)

§ סעיף 15 — סעיף 15

צדדים רשאים לקבוע מראש פיצוי מוסכם להפרה. הנפגע זכאי לו **ללא הוכחת נזק**; ואולם בית המשפט רשאי **להפחיתו** (ולא לבטלו) אם נקבע **ללא יחס סביר** לנזק שאפשר היה לצפות בעת הכריתה.

שאלה	תשובה
האם הנפגע חייב להוכיח נזק?	לא, בפיצוי מוסכם
האם אפשר לתבוע גם פיצוי מלא?	הנפגע רשאי לבחור: פיצוי מוסכם או (לחלופין) פיצוי בגין הנזק שנגרם בפועל
האם בית המשפט רשאי להתערב?	כן, להפחתה (אם ללא יחס סביר); לא לביטול
"כל הפרה" בחוזה – פיצוי מוסכם אחיד	תניה גורפת: ייתכן שלא תהיה סבירה לכל הפרה

16.6 שלד לפתרון שאלה

1. **הפרה:** האם יש הפרה (פרק 10).
2. **תרופות:** אכיפה/ביטול (פרק 11); האם ביטול? אם כן – סעיף 9 (השבה) וסעיף 11.
3. **פיצויי ציפייה (10):** נזק, סיבתיות, **צפיות בעת הכריתה**.
4. **סעיף 13:** נזק לא ממוני (לא לתאגיד).
5. **סעיף 14:** הקטנת נזק.
6. **סעיף 15:** יש פיצוי מוסכם? יחס סביר?
7. **עשיית עושר:** רווחי המפר (אדרס) כחלופה.

16.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות

- "הצפיות נבחנת בעת ההפרה" – לא. בעת כריתת החוזה.
- "סעיף 11 דורש הוכחת נזק" – לא. פיצוי לפי הפרש מחיר.
- "פיצוי מוסכם חייב להיות מדויק" – לא; אפשר להפחית אם אין יחס סביר, לא לבטל.
- "לתאגיד מגיעה עוגמת נפש" – לא.
- "הקטנת נזק אינה חובה" – היא חובה; אחרת מופחת הפיצוי.
- "אחרי ביטול אין פיצויים" – יש: בביטול בשל הפרה אפשר לצרף פיצויי קיום.

16.8 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — שורה תחתונה

- סעיף 10: פיצויי ציפייה + צפיות בעת הכריתה.
- סעיף 11: הפרש מחיר ללא הוכחת נזק; סעיף 9: השבה.
- סעיף 13: לא ממוני; 14: הקטנת נזק; 15: מוסכם – אפשר להפחית.
- אדרס: רווחי המפר בעשיית עושר.